denúncias de pedofilia destruíram a vida de inocentes[84]. Diferente é a situação do uso, pelo mesmo jornal, num anúncio publicitário, da imagem de uma modelo sem autorização (haverá, nesse caso, violação ao direito de imagem, porém não do direito à honra). Não só aquele que teve sua imagem usada sem autorização poderá reclamar, mas também seus herdeiros, em caso de falecimento.

Pois bem, supondo que consigamos, no caso concreto, distinguir as duas figuras conceituais: a) violação da imagem sem violação à honra; b) violação à imagem com violação à honra (STJ, REsp. 436.070). As sanções civis são as mesmas? Falamos, aqui, apenas da responsabilidade civil, e não de tutelas preventivas (para evitar a violação) ou mesmo de tutelas específicas, como o direito de resposta. No caso de violação à imagem com violação à honra, a situação é mais fácil: a indenização compreenderá os danos morais, sem prejuízo dos danos materiais porventura configurados (digamos que alguém, acusado de pedofilia, foi demitido do emprego, ou teve sua escola infantil fechada). No caso de violação à imagem *sem violação à honra* entendemos que só o caso concreto poderá definir se são devidas as indenizações por dano material ou moral ou apenas uma delas.

13.1.1. A questão do false light: o dever de contextualizar as imagens

A contextualização é fundamental no que diz respeito ao direito à imagem. Os juristas norte-americanos aludem ao fenômeno chamado *false light*, que seriam imagens – usadas de modo descontextualizado – que indicam situações distintas daquelas que elas realmente revelam (por exemplo, usar uma foto de dois irmãos adultos se abraçando ou se beijando, numa matéria jornalística que fala sobre os casais homoafetivos). Uma imagem num contexto indevido pode induzir a compreensões equivocadas.

Os jornais em geral possuem um banco de fotos e costumam usá-lo sem muita preocupação com o contexto em que a pessoa foi fotografada. Esse uso descompromissado poderá, desde que as circunstâncias perfaçam hipótese de dano indenizável, gerar responsabilidade civil (mais dificilmente em casos de pessoas públicas). Se nem todo uso configura abuso, há casos em que ele claramente se verifica. Lembremos, ademais, que a vítima, do outro lado, pouco ou nada poderá fazer. Pode ser devastadora a utilização indevida da imagem pela imprensa, sobretudo se aliada à violação à honra. O STJ corretamente já delimitou que "o direito de informar deve ser garantido, observados os seguintes parâmetros: (i) o grau de utilidade para o público do fato informado por meio da imagem; (ii) o grau de atualidade da imagem; (iii) o grau de necessidade da veiculação da imagem para informar o fato; (iv) o grau de preservação do contexto originário do qual a imagem foi colhida" (STJ, REsp 794.586).

[84] Julgando o caso da Escola Base – ocorrido em 1994, quando, conforme dissemos, falsas denúncias de abuso sexual destruíram a vida de inocentes, proprietários de uma escola de educação infantil – o STJ, confirmando decisão do TJSP, concedeu, a cada uma das vítimas, o valor de R$ 250 mil a título de danos morais, contra o jornal que veiculou as acusações. O STJ entendeu que o valor em questão não é abusivo, diante das gravíssimas (e falsas) acusações (STJ, Ag. 801.495).

13.2. O uso da imagem alheia e a questão do eventual proveito obtido

A imagem é direito autônomo. Já vimos que ela pode ser violada isoladamente ou junto com a honra. Em nenhum dos dois casos, porém, faz-se necessária a prova de que houve prejuízo. O STJ, aliás, através da Súmula 403, estabeleceu: "Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais". Há quem entenda que "a mera utilização inconsentida da imagem gera o dever de indenizar por danos morais, pouco importando que a projeção da imagem tenha se dado de forma não injuriosa, não atentatória à reputação da pessoa". Entendemos que na hipótese do uso da imagem alheia *sem* violação à honra só os casos concretos dirão se a indenização dirá respeito a danos materiais ou morais (podemos, nessas hipóteses, estar diante apenas de um deles, não dos dois).

Se o uso da imagem alheia, sem autorização, se faz com fins comerciais, o dano material é evidente[85]. Isso vale até mesmo para a imagem de pessoas já mortas. A publicidade, aliás, vale-se com frequência de imagens de pessoas já mortas, porém célebres. Em determinada ocasião, o uso de fotos de "Lampião" e "Maria Bonita", em propaganda comercial, ensejou indenização aos herdeiros. Outro aspecto conexo é o seguinte: o valor da indenização não tem como teto o lucro do agressor, podendo ir além. Se é certo que a lesão à imagem não depende da circunstância do ofensor ter auferido lucro com o ilícito, se ele auferiu, esse valor não pode ser usado como limite máximo para a quantificação da indenização. Aliás, mesmo se o ofensor teve prejuízo com o negócio, o uso indevido da imagem alheia é indenizável.

13.3. Autorizações para uso da imagem: interpretação restrita

A cessão, onerosa ou gratuita, de imagem deve ser interpretada restritivamente. Se alguém, por exemplo, dá entrevista e permite que sua foto seja usada em revista técnica – com viés econômico, jurídico etc. – isso não autoriza que o mesmo grupo editorial use a foto em outras revistas, de celebridades e fofocas, por exemplo. Em abril de 2017, houve, em alguns blogs, publicidades digitais feitas por uma corretora de valores com a foto do ex-jogador de futebol Müller, com a seguinte frase: "Você se lembra do craque Müller? Ele ganhou milhões, mas não guardou dinheiro algum. Saiba como virar esse jogo". Por certo, publicidades como essa *não podem ser feitas* sem a autorização da pessoa cuja imagem é usada.

13.3.1. Consentimento para captação não é consentimento para publicação

A questão diz respeito a algo bem comum atualmente. Danos graves têm surgido daí. Os exemplos possíveis são muitos, fiquemos com o mais comum deles: a namorada envia fotos nuas – os célebres *nudes* – para o namorado. Ele, depois, por uma

[85] Porém mesmo essa afirmação deve ser contextualizada e lida à luz das circunstâncias concretas. Em maio de 2017, houve o célebre interrogatório judicial do ex-presidente Lula pelo juiz Sérgio Moro, oportunidade em que o réu afirmou que boa parte das responsabilidades discutidas no processo penal eram de sua esposa recentemente falecida, Marisa. Poucos dias depois do interrogatório foi o dia das mães. A Loja de Departamento Marisa, então, realizou a seguinte publicidade, que gerou enorme polêmica na internet: "Se sua mãe ficar sem presente, a culpa não é da Marisa".

razão qualquer, publica as fotos na internet. Ou pior: o namorado grava, em vídeo, as relações sexuais que teve com a namorada (com ou sem consentimento dela). E depois do fim do namoro, por intuito de vingança ou outra razão qualquer, ele divulga esse conteúdo na internet. A conduta, por certo, é ilícita, e o potencial danoso é imenso para a vítima. Não são poucos os casos de pessoas que mudam de cidade, de emprego por casos assim. Também não são raros suicídios, sobretudo de adolescentes. Trata-se, sem dúvida, de dano indenizável. O que precisa ficar claro é aquilo que dissemos no tópico: o consentimento para a captação não é consentimento para publicação. Sobretudo se a foto não foi tirada em local público, sobretudo se a foto ou o vídeo retrata algum momento íntimo. Para além de tudo isso, a Lei nº 13.772/18 criminalizou o registro não autorizado de conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado, estabelecendo um tipo penal encartado no art. 216-B do Código Penal, com pena de detenção de seis meses a um ano, além de multa.

E a orientação também vale para outros contextos. É muito comum, por exemplo, o uso de imagem de cidadãos – sobretudo brasileiros anônimos, humildes, sempre lembrados nessas horas – em programas eleitorais. A pessoa pode até autorizar a foto. O uso em contexto político não é presumido. O uso dessas imagens sem autorização é ilícito, e gera direito à indenização compensatória (STJ, REsp 1.217.422). Não importa se a pessoa que teve a imagem usada é civilmente capaz ou incapaz.

13.4. Fotos de multidões e direito à imagem

> *"Mas eu queria falar do Brasil. Entre nós, a multidão é mais recente. Tenho, diante de mim, uma fotografia da avenida Rio Branco, do princípio do século. O Municipal acabara de ser construído. Eis o que vejo: não há grupos. O brasileiro ainda andava só. Saía e voltava desacompanhado. Quando três brasileiros se juntavam, as instituições tremiam em cima dos sapatos. Eu diria que o autor da primeira multidão foi o Fla-Flu. E, pouco a pouco, começamos a adquirir o hábito da multidão".*
>
> Nelson Rodrigues

A imagem, se é um direito da personalidade com as especificidades que apontamos, não cria uma redoma ao redor de cada um de nós. Não seria, decerto, razoável nem mesmo possível essa interpretação. Não há, metaforicamente falando, uma espécie de capa jurídica que cubra cada ser humano ao sair de casa, impedindo que sejam feitos os usos normais, comuns e esperados da nossa imagem à luz dos usos e costumes da sociedade contemporânea.

Não caberia, nesse sentido – seria irrealístico e ingênuo – pretender que os jornais, a cada edição, obtenham centenas de autorizações para uso de imagem. Imagine-se a cobertura de uma Copa do Mundo. Ninguém razoavelmente diria que seriam ilícitas e indevidas todas as imagens feitas sem autorização[86]. Fotos e vídeos

[86] Há casos folclóricos. Num deles, ocorrido há algumas décadas, um sujeito, procurado pela polícia federal por significativo desfalque nos cofres públicos brasileiros, foi flagrado pelas câmeras de televisão na arquibancada de um ginásio no exterior, assistindo a um jogo de vôlei do Brasil nas Olimpíadas.

feitos dentro ou ao redor dos estádios fazem parte da cobertura jornalística esperada. Mesmo sem cogitar de eventos de grande porte, o jornalismo, em nossas práticas culturais, faz-se diariamente sem que essas centenas ou milhares de autorizações sejam solicitadas.

Nesse contexto – e para ficar num único exemplo – não viola o direito à imagem fotos de lugares, públicos, como praias e praças, em que aparecem várias pessoas. É possível – só a análise concreta dirá – que, mesmo nesses locais, haja violação à imagem, se o fotógrafo destaca a imagem de alguém, porque nesse caso não é o local da captação que importa, mas a imagem captada. Também não nos parece que haja violação nas câmeras em vias públicas (tem sido cada vez mais comum, no Brasil e em outros países, que haja câmeras de segurança nas ruas, como modo de otimizar e deslocar os policiais e agentes de trânsito para os pontos de maior necessidade).

13.5. Imagens de crianças e adolescentes

A criança e o adolescente têm direito ao resguardo da imagem e intimidade. Não cabe divulgar imagens nem crianças ou adolescentes, nem mesmo quando se tratar de menor infrator. A Lei nº 10.764, de 2003 alterou o art. 143 do Estatuto da Criança e do Adolescente, dispondo que ele passou a ter a seguinte redação: "Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome". O STJ decidiu a propósito: "Pretensão ressarcitória visando à compensação de danos extrapatrimoniais deduzida por adolescente que teve sua fotografia (imagem) veiculada em matéria jornalística, em que se notificou a prática de roubo em casa lotérica, a despeito da expressa vedação inserta no parágrafo único do artigo 143 do Estatuto da Criança e Adolescente (Lei nº 8.069/90)" (STJ, REsp 1.297.660).

Hoje é comum o envio de *nudes* por adolescentes para seus namorados ou namoradas. Com alguma frequência, essas fotos são compartilhadas publicamente depois (*revenge porn*). Poderá haver, nessa situação, dano indenizável. Sob o aspecto criminal, quando o responsável pela divulgação de foto alheia de criança ou adolescente é maior de 18 anos, o Ministério Público Federal realiza a persecução criminal desses crimes (que têm aumentado muito). Voltando ao direito civil, sabemos que certas ações ou omissões causam danos cujos prejuízos são presumidos, não precisam ser provados. O STJ, em 2017, decidiu que agressão à criança dispensa prova de dano moral. Trata-se de dano moral *in re ipsa*. No caso, uma mulher foi condenada a pagar quatro mil reais a título de danos morais por ter agredido – física e verbalmente – uma criança de dez anos que havia brigado com sua filha na escola (STJ, REsp 1.642.318). Já em 2018 o STJ entendeu que a ofensa à dignidade de crianças e adolescentes – humilhados por quadros de programa televisivo que os exibe situações discriminatórias – gera dano moral coletivo (também *in re ipsa*, segundo o tribunal). No caso os menores tiveram suas origens biológicas devassadas e tratada de forma jocosa (STJ, REsp 1.517.973).

13.6. Direito à imagem e a condição social do ofendido

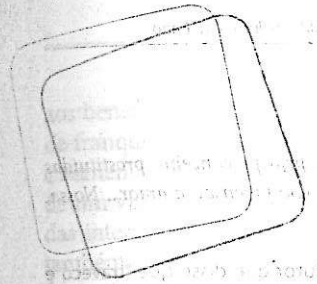
"Minha vida é como filmes de mocinho,
Acabei vencendo quase no final".

Cartola

"Pobre tem que ter um triste amor à honestidade".

Guimarães Rosa

Talvez muitos de nós sequer se deem conta, mas o direito à imagem costuma ser encarado de modo diferente, dependendo da condição econômica ou social da vítima. Esses desníveis de exigência – o que viola o direito de imagem do rico não viola o do pobre – precisam ser submetidos a testes de consistência constitucional, para que não incidamos em práticas discriminatórias, sobretudo ao interpretar e aplicar o direito. Por mais degradante que seja a situação vivida por alguém, o direito à imagem não se esfarela. Pelo contrário, talvez justamente aí a vítima mais precise dele, ainda que no momento não tenha esse discernimento. Há alguns anos a Polícia de Londres lançou uma campanha publicitária assim intitulada: "Não deixem que traficantes mudem a cara do seu bairro". Junto com o *slogan*, havia fotos, impressionantes e terríveis, de mulheres viciadas. As fotos (três de cada mulher) mostravam, em poucos meses, a espantosa degradação provocada pela droga, tornando, em pouco tempo, irreconhecíveis (fisicamente) as pessoas. Registre-se que as fotos foram tiradas, todas, pela polícia, nas sucessivas passagens das viciadas pela polícia. Por mais louvável que seja o propósito (e é), a exposição da imagem alheia, sobretudo em condições tão terríveis, jamais poderia ser feita sem os respectivos consentimentos. Há clara violação do direito à imagem, presente tudo o que antes dissemos.



2

UM OLHAR DO DIREITO CIVIL PARA O NOVO

"Nem todas as verdades são para todos os ouvidos".

Umberto Eco

"Está claro que creio em tudo isso. Eu justamente creio em tudo. Creio até no contrário disso. A minha faculdade de crer é ilimitada. Não compreendendo por que as pessoas creem numas coisas e noutras não. Tudo é crível. Principalmente o incrível. Não estou fazendo paradoxo. A vida é que já é por si mesma paradoxal, desde que seja vista não apenas pela superfície".

Cecília Meireles

1. DIREITOS QUE ESTÃO NA PAUTA DO SÉCULO XXI

Não nos cabe, aqui – nem haveria espaço para tanto – desenvolver os temas apresentados. Nosso intuito é outro. É apenas apresentar, do modo mais breve possível, certas questões que estão sendo discutidas em relação aos direitos da personalidade e aos direitos fundamentais, como forma de introduzir esses temas para o leitor, como informação básica.

1.1. Direito à identidade sexual

> *"É mesmo? Pessoas que vivem machucadas pelo preconceito, prostituídas pela falta de empregos, carentes de respeito, compreensão e amor... Nossa, realmente hilário".*
>
> (Tati Bernardi, em resposta a um produtor que disse que "traveco é sempre engraçado").

O direito do século XXI trabalha cada vez mais com o direito à diferença e com o reconhecimento de identidades. A autodeterminação deve ser valorizada e respeitada, como componente integrante da dignidade humana. Sabemos, hoje, que os direitos fundamentais são frutos de construção histórica, não caem do céu, resultam de lutas e de construções coletivas não só para valorizar as pessoas em termos de equidade mas também para fundamentar o exercício do poder a partir desses direitos[1]. O sexo hoje é visto não como algo adquirido quando da concepção, mas de uma forma mais cultural e dinâmica. Isto é, não é algo irreversível – a ser mantido vitaliciamente, ainda que com profundos sofrimentos quanto à própria identidade –, mas algo de certo modo construído, com respeito ao percurso existencial de cada um[2].

Sabemos quão fortes foram (e são) os preconceitos contra quem realizou opções sexuais que fogem do padrão clássico entre homem e mulher. Houve, contudo, inegáveis avanços. O panorama – social, jurisprudencial e doutrinário – é outro, sem dúvida, tendo como paradigma de comparação o que existia, por exemplo, anteriormente à Constituição de 1988, e mesmo na década seguinte. O STF aceitou, de modo unânime, a união estável para casais do mesmo sexo (trata-se de valioso caso de aplicação dos direitos fundamentais às relações privadas)[3]. As liberdades existenciais fundamentais – como, por exemplo, a de escolher o parceiro afetivo e, eventualmente, casar-se com ele – devem ser em tudo as mesmas, não importa a orientação sexual do casal. Caminhamos, portanto, em direção a padrões de igual respeito e consideração para todos os casais, não importando a orientação sexual.

Em relação ao casamento de pessoas do mesmo sexo, Daniel Sarmento afirmou: "Na verdade, é exatamente porque o casamento é tão valorizado na nossa cultura, simbolizando no imaginário social o vínculo amoroso mais sólido que duas pessoas podem manter, que o acesso a ele tem de ocorrer em termos absolutamente igualitários e democráticos. Portanto, trata-se não somente de assegurar aos homossexuais o acesso

[1] HABERMAS, Jürgen. *Between Facts and Norms: contributions to a discourse theory of law and democracy*. Cambridge: The MIT Press, 1996, p. 119. Habermas menciona ainda, em outro texto, que a dignidade humana não é apenas uma expressão classificatória, mas a "fonte moral" da qual todos os direitos fundamentais derivam seu conteúdo.

[2] Cf. RODOTÁ, Stefano. Présenttatios générale des problémes liés au transsexualisme. In: *Transsexualisme, médecine et droit*. XXIII Coloque de Droit Européen, Pays Bas, Vrije Universiteit, 1993.

[3] Isso se deu não obstante a Constituição da República prever, no art. 226, § 3º, que "para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento". Há, portanto, na Constituição, a menção a "o homem e a mulher", em relação à união estável. Queremos, por acaso, exemplo melhor de que a literalidade da norma é apenas o ponto de partida de uma atividade – muito mais rica e complexa – de interpretação? O STF foi além da literalidade da regra. A construção dos horizontes de sentido das normas, portanto, parte do texto, mas não é o texto.

aos benefícios materiais que advém do *status* de casada ou de casado, como também de franquear, aos que optarem por isso, as portas do universo simbólico associado ao casamento, que, para muitos, denota, em seu máximo grau, a respeitabilidade social de um vínculo afetivo. É por isso – porque os símbolos importam tanto na economia das interações sociais – que o *nome da coisa* é relevante: os homossexuais devem ter também o direito ao casamento, e não apenas à união estável, ou a qualquer outra figura jurídica com que se pretenda enquadrar as famílias que constituírem"[4].

A família, cada vez mais, é vista como um grupo social baseado fundamentalmente nos laços de afetividade. Ou seja, "não como portadora de um interesse superior e superindividual, mas, sim, em função da realização das exigências humanas, como lugar onde se desenvolve a pessoa"[5]. A justificação da família, portanto, apenas a partir de funções políticas, econômicas ou mesmo de procriação não mais se sustenta, pelo menos não com exclusividade. O afeto vem, ou deve vir, em primeiro lugar.

Julgando caso de troca de nome (no registro público) de alguém que havia realizado cirurgia de redesignação sexual, o STJ, em acórdão relatado pela Ministra Nancy Andrighi, assim se manifestou: "A afirmação da identidade sexual, compreendida pela dignidade humana, encerra a realização da dignidade, no que tange à possibilidade de expressar todos os atributos e características do gênero imanente a cada pessoa. Para o transexual, ter uma vida digna importa em ver reconhecida a sua identidade sexual, sob a ótica psicossocial, a refletir a verdade real por ele vivenciada e que se reflete na sociedade" (STJ, REsp 1.008.398). A jurisprudência admitia não apenas a troca do nome, mas também a troca, no registro civil, do próprio gênero (de masculino para feminino, por exemplo, nos casos em que tivesse sido feita a cirurgia de redesignação sexual). Porém mesmo isso já ficou para trás. Em 2017 o STJ deu um passo além. Admitiu a retificação do registro de nascimento para troca de prenome e do gênero (masculino para feminino), sem que para isso seja necessária a realização de cirurgia de transgenitalização. Argumentou-se que "à luz dos direitos fundamentais corolários do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, infere-se que o direito dos transexuais à retificação do sexo no registro civil não pode ficar condicionado à exigência de realização da cirurgia de transgenitalização, para muitos inatingível do ponto de vista financeiro (como parece ser o caso em exame) ou mesmo inviável do ponto de vista médico" (STJ, REsp 1.626.739).

1.2. Direito à autodeterminação informativa e paper *less society*: entre o mundo físico-convencional e o mundo digital

A expressão foi criada e desenvolvida por um dos grandes juristas de nosso tempo, Stefano Rodotà, Professor Titular de Direito Civil da Universidade *La Sapienza*, em Roma. Ele sustenta que se trata do direito de manter controle sobre as próprias

[4] SARMENTO, Daniel. Casamento e união estável entre pessoas do mesmo sexo: perspectivas constitucionais. SARMENTO, Daniel; IKAWA, Daniela; PIOVESAN, Flávia (Coords). *Igualdade, diferença e direitos humanos*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 656. Conferir ainda sobre o tema: NUSSBAUM, Martha C. *Sex and Social Justice*. Oxford: Oxford University Press, 1999; BOZON, Michel. *Sociologia da Sexualidade*. Trad. Maria de Lourdes Menezes. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2004. Já citamos, no primeiro capítulo, trechos do relevante voto do Min. Celso de Mello na na ADIN nº 3.300-DF, relativa ao tema.

[5] PERLINGIERI, Pietro. *Perfis do Direito Civil*. Trad. Maria Cristina de Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 243.

informações, de modo a modular a construção da própria esfera privada. Sustenta o professor que não se trata do antigo "direito a ficar só". Este dizia respeito à vida privada e familiar e expressava, sobretudo, o padrão mental individualista dos séculos passados, quando o poder exauria-se na exclusão da interferência de outrem (uma tutela estática e negativa). Já o direito à autodeterminação informativa, ao contrário, estabelece princípios e regras sobre o tratamento dos dados e se concretiza em poderes de intervenção (tutela plural e dinâmica)[6]. A legislação, no caso, não deve se ater a formas disciplinares casuísticas, mas a princípios.

O Marco Civil da internet – Lei n. 12.965/2014 – segue essa tendência, e é composto por normas fundamentalmente (não exclusivamente) principiológicas. Nesse contexto, prevê que a disciplina da internet no Brasil se baseia na liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento, na linha das garantias constitucionais. A privacidade também é protegida, bem como os dados pessoais. Preserva-se e garante-se a neutralidade de rede[7] (ponto de intensa discussão durante os debates legislativos). Protege-se ainda a natureza participativa da rede (não poderia, dizemos nós, ser diferente), e contempla-se a possibilidade de responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades. Por certo, a previsão é puramente exemplificativa, e não exclui outros princípios, venham de fontes nacionais ou internacionais.

Reconhece, no art. 2º, que a disciplina do uso da internet tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais. São fundamentos ainda do uso da internet a pluralidade, a diversidade, a abertura e a colaboração, a livre iniciativa, a livre concorrência, a defesa do consumidor e a finalidade social da rede. Reconhece a lei, como não poderia deixar de ser, a escala mundial da internet. Em relação ao tópico que estamos tratando, relevante mencionar que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que impliquem ofensa à inviolabilidade e ao sigilo das comunicações privadas pela internet (art. 8º, I).

Seja como for, algo é certo: o mundo digital potencializa enormemente os danos. As informações lá postas trazem consigo duas peculiaridades: a) dificilmente conseguem, uma vez inseridas, ser totalmente eliminadas (na melhor das hipóteses, é copiada por alguém, que depois pode sempre disponibilizar em outro lugar)[8]; b) tem uma tendência espantosa de difusão: expande-se exponencialmente; e se a foto, vídeo, informação ou comentário é ofensivo, os danos são incalculáveis. Bem por isso, ou os provedores, uma vez avisados, retiram rapidamente a ofensa do ar, ou respondem solidariamente pelos danos.

[6] RODOTÁ, Stefano. *A vida na sociedade de vigilância. A privacidade hoje.* Organização e apresentação de Maria Celina Bodin de Moraes. Tradução de Danilo Doneda, Luciana Doneda e Caitlin Mulholland. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 3/10 e passim.

[7] O art. 9º prevê a propósito: "O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação". O § 3º prevê ainda que na provisão de conexão à internet, onerosa ou gratuita, bem como na transmissão, comutação ou roteamento, é vedado bloquear, monitorar, filtrar ou analisar o conteúdo dos pacotes de dados.

[8] Em sentido semelhante, ROSEN, Jeffrey. The web means the end of forgetting. *New York Times*, 21 de julho de 2010. Também, RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade da vigilância: a privacidade hoje.* Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 42.

No *bullying* convencional, por assim dizer, as agressões acontecem no mundo físico-tradicional. No digital, as agressões são virtuais, e talvez ainda mais terríveis, diante do peso que as redes sociais têm para os adolescentes de hoje (basta lembrar da onda de suicídios e mutilações de adolescentes, em 2017, a partir do jogo *Baleia Azul*). Não só isso, houve no Brasil e no mundo muitíssimos casos de suicídios relacionados ao *bullying* digital. Massacra-se, cruelmente, adolescentes (quase sempre colegas da escola), com montagens pornográficas, xingamentos e ameaças constantes[9]. Em grande parte dos casos, o ato digital de agressão ocorre em casa, fora do horário das aulas e das sedes físicas dos estabelecimentos de ensino. Como não responsabilizar os pais dos agressores? Sem que possamos excluir a vigilância (e a responsabilidade civil) das escolas, públicas ou privadas, parece intuitivo que não podemos, em absoluto, isentar os pais. Mesmo porque, no mundo veloz e inefável que vivemos, como definir de onde partiu a agressão? As agressões, no caso, podem ser facilmente postadas do celular. Onde se estava quando se enviou a mensagem agressiva? Na escola? Em casa? Na rua? Isso tem relevância jurídica?

Tanto o *bullying* quanto o *cyberbullying* buscam desestabilizar psicologicamente o ofendido. A jurisprudência já teve oportunidade de condenar civilmente a mãe pelo *cyberbullying* praticado pelo filho menor, que criou página na internet exclusivamente para ofender colega de classe, com fatos e imagens extremamente agressivas (TJRJ, AC 7003750094). Outro aspecto particularmente difícil é a quantificação do dano – não só aqui, mas também aqui. No mundo digital, uma informação caluniosa, por exemplo, tem um potencial expansivo imenso, inesgotável. Isso deve ser levado em conta na quantificação dos danos.

Por outro lado, há, ninguém duvida, aspectos altamente positivos nas novas possibilidades digitais. A tecnologia reduz custos operacionais dos deslocamentos, interliga pessoas e comunidades, diminui o uso de papel e a necessidade de estocagem física de documentos. As gerações que cresceram e foram educadas longe do mundo digital não se sentem confortáveis com essa "fuga do papel", digamos assim (*paper less society*). A desmaterialização é uma tendência irreversível, gostemos ou não. Nesse contexto, nota-se uma progressiva desmaterialização dos bens. Não só a forma de aquisição é digital (pedimos, por exemplo, táxis ou pizzas pela internet), como os próprios serviços se desmaterializam (pensemos, por exemplo, num *e-book*. Não há bem físico palpável, nos moldes do mundo físico-convencional. Os processos judiciais migram, cada vez mais, para o mundo digital, abandonando o papel).

Seja como for, vivemos dias em que muitos questionam se não está havendo o "fim da privacidade". Rodotà menciona: "Mesmo antes do 11 de setembro, particularmente por conta de exigências do mercado e da tendência de montagem de bancos de dados cada vez maiores de consumidores e de seus comportamentos, havia comentários sobre o fim da privacidade. Atualmente, no entanto, se percebemos o modo como o mundo está mudando, emerge uma questão mais radical para

[9] Fala-se, no Brasil, em certos meios, na criação de uma espécie de "Lei Maria da Penha" para o mundo digital. São frequentes casos de ex-companheiros que postam cenas de sexo com as parceiras afetivas que tiveram, e com isso destroem as vidas das garotas. Ficou célebre, no Brasil, em outubro de 2013, um caso desse teor ocorrido com uma jovem de Goiânia.

fundamentar seu acórdão, lembrou que a jurisprudência alemã já abordou o tema, adotando semelhante solução. Em julgado proferido em 31/1/1989 e publicado no periódico jurídico NJW (*Neue Juristische Woche*) 1989, 891, o Tribunal Constitucional Alemão (*BVerfG*) afirmou que "os direitos da personalidade (Art. 2 Par. 1º e Art. 1º Par. 1º da Constituição Alemã) contemplam o direito ao conhecimento da própria origem genética". Aliás, entre nós, o ECA prevê que "o adotado tem direito de conhecer sua origem biológica" (ECA, art. 48, com a redação dada pela Lei n. 12.010/2009).

1.4. Direito de não saber

"As perguntas nunca são indiscretas.
As respostas é que às vezes são".

Oscar Wilde

Uma primeira pergunta se põe: existe, de fato, esse direito? De que se trata?

Cuida-se de discussão que traz certo sabor inusitado: haveria, em relação aos dados genéticos, o direito de não saber? Realizados, digamos, determinados exames ou pesquisas, a pessoa envolvida pode sempre esgrimir seu direito de não saber dos resultados? Esse direito seria oponível a qualquer outra pessoa? Seria oponível a familiares, a possíveis empregadores, ao Estado? Imaginemos, por exemplo, que determinados testes genéticos apontem a predisposição para esclerose múltipla, haveria interesse e utilidade na comunicação ao portador da referida tendência genética (sobretudo nos casos em que nada se pode fazer preventivamente)? E se, por exemplo, a predisposição para determinadas doenças futuras for usada pelos possíveis empregadores para contratar – ou, melhor dizendo, *não contratar* – prováveis empregados?

Em hipótese não idêntica, mas algo semelhante, o STJ julgou caso cujos contornos fáticos foram os seguintes: um cidadão solicitou determinados exames (na solicitação, porém, *não constava* o exame acerca do vírus HIV). Ao receber os resultados, porém, deparou-se com a notícia que era portador do vírus da AIDS, mesmo sem ter solicitado tal exame. O STJ, por maioria, no *leading case* relativo ao tema, decidiu que tal dano não é indenizável. O voto vencedor argumenta ainda que o abalo psíquico, a rigor, provém do fato do indivíduo ser portador do HIV, fato não causado pelo hospital, fato alheio ao nexo causal imputado à conduta hospitalar[15]. Por

[15] A maioria entendeu que "sob o prisma individual, o direito do indivíduo não saber que é portador do vírus HIV (caso se entenda que este seja um direito seu, decorrente de sua intimidade), sucumbe, é suplantado por um direito maior, qual seja, o direito à vida, o direito à vida com mais saúde, o direito à vida mais longeva e saudável. Mesmo que o indivíduo não tenha interesse ou não queira ter conhecimento sobre a enfermidade que lhe acomete (seja qual for a razão), a informação correta e sigilosa sobre seu estado de saúde dada pelo hospital ou laboratório, ainda que de forma involuntária, não tem o condão de afrontar sua intimidade, na medida em que lhe proporciona a proteção a um direito maior". Continua: "Sob o enfoque do interesse público, assinala-se que a opção de o paciente submeter-se ou não a um tratamento de combate ao vírus HIV, que, ressalte-se, somente se tornou possível e, certamente, mais eficaz graças ao conhecimento da doença, dado por ato involuntário do hospital, é de seu exclusivo arbítrio. Entretanto, o comportamento destinado a omitir-se sobre o conhecimento da doença que, em última análise, gera condutas igualmente omissivas quanto à prevenção e disseminação do vírus HIV, vai de encontro aos anseios sociais" (STJ, REsp 1.195.995, rel. p/ acórdão Min. Massami Uyeda). Já o voto vencido, da sempre corajosa e brilhante Ministra Nancy Andrighi, consigna ser "possível a condenação de hospital ao pagamento de indenização por dano moral a paciente na hipótese de equívoco cometido por preposto do hospital que realizou exame diverso do autorizado, com a consequente descoberta e comunicação de ser o paciente portador do vírus HIV, porque ainda que a informação não tenha sido divulgada a terceiros, trata-se de indevida invasão na esfera privada do paciente, investigação abusiva da vida alheia, conduta negligente que viola a intimidade, sendo a responsabilidade do hospital objetiva pelos atos de seus prepostos". Trata-se, como se vê, de outra forma (possível e jurídica) de abordar o tema, vislumbrando a ocorrência de acidente de consumo (caracterizado pela falha na prestação de serviço) e, ainda, caracterizando conduta negligente que violaria a intimidade.

outro lado, é preocupante e questionável a argumentação do voto vencedor, trazendo muitas vezes a questão do interesse público (conforme contextualizamos no primeiro capítulo). Trata-se, sabemos, de conceito jurídico indeterminado, amplíssimo e vasto, que pode comportar, dentro de si, conteúdos não só diversos, mas antagônicos.

O direito de não saber pode ser abordado em outro contexto, alheio à questão dos dados genéticos. Há outras dimensões, bem distintas, do problema. Por exemplo, houve – especialmente na Argentina e no Chile – casos dramáticos, com intensa repercussão social. Casos que trouxeram delicados dilemas (envolvendo o direito de não saber e crimes do regime militar). A questão se põe do seguinte modo: os regimes militares torturavam e assassinavam os pais biológicos de determinada criança (muitas vezes, recém-nascida). Os torturadores e assassinos entregavam a criança para uma família amiga do regime militar. Três ou quatro décadas depois, os crimes vêm à tona. Essa criança, hoje um adulto, tem o direito de não saber que as pessoas que ela tem como pais escondem, na verdade, um obscuro e no mínimo conivente passado?

A legitimidade de uma decisão, nas democracias constitucionais contemporâneas, é aferida não só pelas formas, mas também pelos conteúdos. Há uma rica e variada interação entre os dois modos de controle. A lei, nesse contexto, perde muito do caráter arbitrário que ostentava no passado e a proporcionalidade é princípio que tem como destinatário também o legislador (dissemos *também*). Aceita-se mais naturalmente, hoje, que a atividade judicial, em alguma medida, tem função criativa, circunstância que se mostra ainda mais forte na jurisdição constitucional[16]. Seja como for, não há, por certo, na matéria deste tópico, respostas definitivas. Convém, apenas, alertar para o contexto em que se dá a discussão e lembrar que muito, neste século, ainda se discutirá acerca do direito à informação genética, em seus vários prismas jurídicos e sociais. Podemos, de todo modo, enxergar o direito de não saber como dimensão da autodeterminação informativa[17].

[16] A propósito, certos autores citam exemplos de nações que ostentam o traço democrático sem, no entanto – pelo menos durante certo período histórico – trazerem a nota institucional da revisão judicial (GRIMM, Dieter. Jurisdição Constitucional e Democracia. *Revista de Direito do Estado*. 4:3, 2006, p. 6-9. De modo semelhante, NINO, Carlos Santiago. *La Constitución de la Democracia Deliberativa*. Barcelona: Gedisa, 1997). A tendência contemporânea, no entanto, parece apontar no sentido de uma progressiva adoção do *judicial review*. Um exemplo eloquente, e muito citado, é a França, que não dispunha de um sistema de controle repressivo de constitucionalidade e passou a adotá-lo depois da reforma constitucional de 2008.

[17] "Na legalidade constitucional, o direito de não saber deve ser tutelado como desdobramento do direito à autodeterminação informativa, que pressupõe que o controle do fluxo de informações que ingressam na esfera privada (...). Como consequência da expansão da privacidade na sociedade de informação, o controle do conteúdo que compõe o acervo informacional impõe a garantia de um poder negativo de excluir da esfera privada determinado tipo de informação, ainda que essa exclusão desafie os padrões sociais e culturais sobre as noções de saúde e vida saudável" (VIVEIROS DE CASTRO, Thamis Dalsenter. Desafios para a tutela do direito de não saber: corpo, autonomia e privacidade. In: MENEZES, Joyceane Bezerra de; TEPEDINO, Gustavo (Coord.). *Autonomia privada, liberdade existencial e direitos fundamentais*. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 191-204).

também ações[22]. Pode ser oponível não só ao Estado, mas também aos particulares (que são, muitas vezes, ofensores desse direito). Há um sistema aberto de proteção. Nesse sentido, o direito ao livre desenvolvimento da personalidade pode complementar, à luz dos casos concretos, o caráter aberto e não taxativo dos direitos da personalidade, ampliando o grau de proteção.

A Constituição alemã, a propósito, no art. 2º, estatuiu: "Todos têm o direito ao livre desenvolvimento de sua personalidade, desde que não violem direitos de outrem e não se choquem contra a ordem constitucional ou a lei moral". Não há taxatividade nesse desenvolvimento, por certo. Trata-se de cláusula aberta e plural. Sem falar que projetos e modos de viver que nos seduziram em determinado momento da vida não necessariamente contarão com nosso apoio décadas depois. Há escolhas da juventude e há escolhas da maturidade. Há muitos modos e formas de se desenvolver como pessoa, e eles estão garantidos pela ordem civil-constitucional. A escolha desses modos e dessas formas deve ser feita pela própria pessoa, de modo livre e autodeterminado. Nem o Estado nem outrem (pais, por exemplo), podem influir nessas escolhas, quando houver, por parte de quem escolhe, discernimento, maturidade e autodeterminação. Trata-se, por certo, de princípio intimamente conectado à dignidade e a liberdade existencial. Tutela-se, aqui, a rica individualidade de cada um de nós.

1.7. Direito à educação domiciliar? A questão do *homeschooling*

O STF, em 2018 – em caso com repercussão geral (RE 888.815) – definiu a questão do *homeschooling* – isto é, a possibilidade do ensino domiciliar. Podem os pais educar os filhos na própria casa, sem mandá-los às escolas públicas ou privadas? Isso seria um meio lícito de cumprir o dever de educação previsto no art. 205 da Constituição?

Sabe-se que nos EUA o tema é bastante discutido, encontrando certo enraizamento cultural ligado a questões religiosas (e também relacionadas à questão da autonomia do indivíduo e da acentuada valorização da liberdade individual). Algumas das decisões da corte americana parecem autorizar que os pais recusem o ensino formal e compulsório aos filhos, mas apenas poderiam fazê-lo por razões religiosas – o que, por certo, não encontra amparo algum na Constituição brasileira. Seja como for, existem leis em vários Estados norte-americanos que autorizam o *homeschooling*. As cortes americanas – seja a Suprema Corte, sejam cortes estaduais – consideram lícita a prática do *homeschooling*, ainda que haja visões opostas expressas nos votos vencidos.

Mas será que a questão deve ser enxergada apenas sob a ótica da liberdade dos pais? Será que é disso mesmo que se trata? O poder-dever de educar é um exercício de liberdade e de escolha? Apenas as visões dos pais devem ser ouvidas? A tendência do direito civil atual – e trazemos o ponto em várias passagens deste livro – é respeitar de modo progressivo a autonomia existencial dos adolescentes, ainda que

[22] Cf. MIRANDA, Felipe Arady. O Direito Fundamental ao Livre Desenvolvimento da Personalidade. *RIDB*, ano 2 (2013), n. 10, 11175-11211.

considerados incapazes pelo Código Civil. A tendência é que sejam cada vez mais ouvidos nas decisões que lhes digam respeito. E ainda: será que afastar a criança do convívio social não implica – em alguma medida – frustrar o livre desenvolvimento de sua personalidade?

Há outras dimensões que sempre surgem no debate: ninguém desconhece que o convívio escolar propicia não apenas educação formal, mas também – talvez até sobretudo – habilidades fundamentais relacionadas à socialização, à formação de laços de amizade, ao desenvolvimento psíquico, à convivência com a diferença etc. Lembremos que o ambiente doméstico também pode ser opressor, e isolar as crianças do mundo exterior nem sempre traz resultados saudáveis.

O tema é reconhecidamente difícil. Talvez um dos mais difíceis. O STF, na linha do que brevemente antecipamos, entendeu que o *homeschooling* não é compatível com ordenamento jurídico brasileiro atual.

1.8. Direito de não nascer? Um tema mal colocado

> *"Sua morte chocou-me porque eu tinha uma distraída confiança em sua energia e em sua capacidade de luta. Julgava-o capaz de raivas e arrebatamentos, nunca de um gesto de desespero. E esse meu engano me dói. Sempre nos sentimos (e na realidade somos) um tanto culpados, quando alguém perto de nós se abandona à morte. Um pouco mais de amizade e atenção de minha parte ou de qualquer de seus amigos poderia talvez tê-lo salvo. Somos desatentos às criaturas que comem e bebem em nossa mesa, e apertam nossa mão. Não vemos, não sentimos o que está perto de nós: como podemos pedir aos outros misericórdia e ternura?".*
>
> Rubem Braga

Tantas e tão variadas – ou absurdas, a depender do ponto de vista – são as formas que os danos podem assumir em nosso século, que tornou-se célebre – a partir do caso *Perruche*, ocorrido na França – a controvérsia acerca do "direito de não nascer". No caso, Nicolas Perruche nasceu com severas deficiências físicas em virtude da rubéola que sua mãe contraiu na gravidez. O tribunal francês concedeu, em 2000, indenização não só aos pais, mas ao próprio Nicolas. Em relação aos pais, porque foram privados da possibilidade de abortar (a a mãe havia formalmente declarado que não gostaria de seguir adiante com a gestação, caso o diagnóstico de rubéola fosse confirmado – hipótese que, na França, autoriza a interrupção da gravidez, até o terceiro mês de gestação)[23]. Em relação à criança, pelos danos que experimentou (que, frise-se, provieram da rubéola, não da conduta dos médicos). Sem falar nos possíveis traumas psicológicos e conflitos emocionais ao saber que sua mãe *preferia não tê-lo* como filho).

[23] Conferir MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. *A responsabilidade civil por presunção de causalidade*. Rio de Janeiro: GZ, 2010, especialmente, sobre o tema, p. 268-275.

Também nos tribunais americanos já foi discutida a questão do *wrongful life*[24], em caso de nascimento de criança com deficiência, não diagnosticada por causa de erro médico (também os pais, nesse caso, pretendiam abortar, se soubessem). Trata-se, cremos, de postura perigosa e incabível no Brasil, que não aceita – corretamente, cremos – o aborto em hipóteses semelhantes. Poderíamos chegar ao perigoso relativismo moral defendido por certos filósofos, que sustentam, por exemplo, que os pais de bebês com deficiência poderiam decidir, junto com os médicos, se a vida da criança deveria continuar[25]. Convém repetir: diante dos valores previstos em nossa Constituição, que privilegiam fortemente a dignidade humana e a solidariedade social, tal pleito não é de ser aceito. Trata-se de algo tão repulsivo e distante das opções valorativas básicas de nossa Constituição que nem se precisa, no ponto, de exaustão argumentativa em sentido contrário.

Voltando ao caso *Perruche*. Tão grande foi a polêmica, e tantos foram os pedidos de indenização que se seguiram, que foi editada uma lei (n. 2002/303) proibindo, de modo explícito, a concessão de indenização por nascimento indesejado, salvo se diretamente vinculado a erro médico. Seja como for, a polêmica (talvez exagerada) decorreu de um erro de perspectiva. Na verdade, se encararmos o caso – não a partir do ângulo de não nascer, ângulo equivocado de abordagem – mas apenas a partir da falha na prestação do serviço, trata-se de prosaico dano indenizável a partir dos pressupostos convencionalmente aplicáveis à matéria. Desse modo, não se trata, a rigor, de indenizar o nascimento indesejado, mas apenas o erro médico que repercutiu severamente na saúde de alguém. Lembremos que os danos futuros são indenizáveis, desde que certos, ou altamente prováveis. A propósito dos danos futuros, esclareça-se que não se trata, como a doutrina ambientalista propõe, de algo peculiar ao direito ambiental, mas algo próprio do direito dos danos do século XXI.

1.9. Direito ao tempo útil (e outras formulações como a *teoria do desvio produtivo*)

O direito não é – nem nunca foi – indiferente ao passar do tempo. O tempo repercute vivamente em múltiplas dimensões jurídicas, gerando aquisição, modificação e extinção de situações jurídicas. Este tópico, porém, trata de outro aspecto: cada vez mais a experiência jurídica dos nossos dias fala no tempo como um bem jurídico. Como algo que pode ser tutelado de modo autônomo. Se o tempo é um bem – e, para muitos de nós, um bem extremamente valioso e escasso nesses dias tão velozes –, e se outros, com suas ações ou omissões injustas, atingem esse bem, esvaziando-o, trata-se de conduta que pode em princípio perfazer um dano indenizável. É uma tendência que se observa nos debates doutrinários e jurisprudenciais.

[24] Pode-se distinguir – como fazem alguns autores – as hipóteses de *wrongful birth* do *wrongful life*. No caso de *wrongful birth*, a ação seria proposta pelos pais. Já nos casos de *wrongful life*, a ação seria proposta pelo próprio doente. Cf. SÁ, Maria de Fátima Freire; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira. *Manual de Biodireito*. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 222/223. Conferir ainda: PUIGELIER, Catherine. O estatuto jurídico do embrião e do feto. *Revista Trimestral de Direito Civil*. Rio de Janeiro: Padma, n. 26, abr./jun. 2006.

[25] SINGER, Peter. *Libertação animal*. Trad. Fátima St. Aubyn. Porto: Via Óptima, 2008; *Ética Prática*. Trad. Álvaro Augusto Fernandes. Lisboa: Gradiva, 2000.

Aliás, um dos paradoxos de nossos dias é este: vivemos numa sociedade reconhecidamente veloz e o tempo "sumiu" para muitos de nós. O dia e suas 24 horas não são suficientes para o que precisamos fazer.

É certo que sob essa expressão – indenização pela perda do tempo livre ou pela perda do tempo útil – situações muito diversas podem se apresentar. Há algo que deve ser visto como denominador comum a todas elas: a superação do limite de tolerabilidade, algo que só pode ser aferido no caso concreto. Isso porque é socialmente comum e aceitável – talvez até inevitável – que todos nós percamos tempo nessa ou naquela atividade, ainda que desagradável. Um exemplo trivial pode citado: o trânsito lento que tanto nos aborrece (não chegamos ainda ao nível civilizatório de poder obter a condenação estatal por danos difusos relacionados ao tempo que perdemos no trânsito). Isso hoje é um bom exemplo do tão falado "mero aborrecimento".

Mas há outras situações, específicas e temperadas de abusividade, relacionadas à perda de tempo útil, em que o dano indenizável tem se mostrado presente. Obrigar, por exemplo, o consumidor a perder dias ou semanas para resolver determinada situação (sobretudo se a situação não foi causada por ele, como na hipótese de uma cobrança indevida ou por engano) pode se mostrar como relevante pelo tempo que se perdeu com isso. Sabemos quão lentas e burocráticas costumam ser essas soluções. Em determinado caso (AREsp 1.260.458) o STJ entendeu haver dano moral quando o consumidor passa por verdadeiro calvário para obter o estorno pretendido (no caso, três anos entre o início da cobrança até a sentença). Isso tem sido denominado de *teoria do desvio produtivo*, ou *teoria do desvio produtivo do consumidor*. Essa abordagem a rigor não é nova, sendo conhecida na jurisprudência anglo-saxã por exemplo. Aliás, entendemos que o tempo perdido pelo lesado não precisa ser "produtivo", isto é, não precisa ter sido desviado do que a vítima teria produzido se estivesse trabalhando. O tempo é bem jurídico autônomo, e o lazer, o ócio, também é valioso, talvez até mais.

Assim, "uma vez compreendido como bem juridicamente tutelável, o tempo passa, de noção de cunho sociológico e filosófico, a objeto de relações jurídicas contemporâneas, em especial das relações de consumo"[26]. Por exemplo, "à frustração do consumidor de adquirir o bem com vício, não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não deu causa, o que, por certo, pode ser evitado – ou, ao menos, atenuado – se o próprio comerciante participar ativamente do processo de reparo" (STJ, REsp 1.634.851). Há controvérsias doutrinárias em relação à caracterização da lesão ao tempo. Seria sempre dano moral? Seria categoria autônoma? Cremos que não se trata de categoria autônoma: em certos casos, superado concretamente o limite de tolerabilidade, a indenização deverá se fazer presente – e esta poderá dizer respeito ao dano moral ou material, e eventualmente até a ambos.

[26] MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo. Lesão ao tempo: configuração e reparação nas relações de consumo. Revista da AJURIS – Porto Alegre, v. 43, n. 141, Dezembro, 2016, pp. 87-113. Ver ainda: MAIA, Maurilio Casas. O dano temporal indenizável e o mero dissabor cronológico no mercado de consumo: quando o tempo é mais que dinheiro. – É dignidade e liberdade. *Revista de Direito do Consumidor*, v. 92, p. 162, 2014; DESSAUNE, Marcos. *Desvio produtivo do consumidor*: o prejuízo do tempo desperdiçado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011; BAROCELLI, Sergio Sebastián. Cuantificación de daños al consumidor por tiempo perdido. Revista de Direito do Consumidor, v. 90, p. 119, 2013.

2. O EXTRAORDINÁRIO DESENVOLVIMENTO DA BIOTECNOLOGIA: DILEMAS ÉTICOS E JURÍDICOS

Basta abrir os jornais, neste conturbado e veloz século, para que nos deparemos com situações inéditas, curiosas, instigantes. Situações em vários aspectos revolucionárias (basta lembrar da incrível descoberta das ondas gravitacionais em 2016, com consequências técnicas e mesmo filosóficas intermináveis). O avanço da ciência nos conduz a resultados impressionantes. Embora não diga respeito propriamente à biotecnologia, cabe transcrever um editorial da *Folha de São Paulo* para ilustrar os incríveis avanços científicos atuais (dentre tantos exemplos possíveis, talvez melhores que esse). Falando a respeito da aterrissagem – pela primeira vez na história humana – de um módulo espacial num cometa (mais especificamente, do módulo espacial *Philae* no cometa *Churyumov*), descreveu: "A tarefa era das mais difíceis. Os comandos da aproximação final estavam todos programados – a distância de 511 milhões de quilômetros entre o corpo celeste e a Terra inviabilizava qualquer intervenção humana de última hora. Sem propulsores para guiá-lo, o módulo dependia, para pousar, exclusivamente da fraquíssima gravidade do cometa, algo como um centésimo de milésimo da terrestre. Além disso, a operação toda, iniciada com o lançamento de um foguete em 2004, desenrolou-se em torno de um objeto irregular, pequeno (meros 4 km de diâmetro) e que viaja à impensável velocidade de 135 mil km/hora". Continua: "Tinha tudo para dar errado – e deu certo. Philae tornou-se o primeiro artefato humano a alcançar um tipo de corpo celeste que desde a Antiguidade fascina" (*Folha de São Paulo*, Editorial "Nessa cauda de cometa", 17/11/2014).

2.1. Questões relativas aos dados genéticos

As últimas décadas revelaram muito à humanidade acerca dos dados genéticos dos seres humanos. Somos, também nisso, singulares. Tal como ocorre com as impressões digitais e a íris dos nossos olhos[27], também nossa identidade genética é única, singular. Mais uma das muitas belezas da criação, como que a nos mostrar que somos belamente individuais e que há muita riqueza nisso.

Nesse contexto, "os dados genéticos têm a capacidade de identificar indivíduos, revelar futuras enfermidades e fornecer informações sobre parentesco, uma vez que englobam quaisquer informações genéticas, desde as mais gerais até as mais específicas. Assim, pode-se dizer que possuem as características de serem *únicos, estruturais, probabilísticos e geracionais*. Os dados genéticos são *únicos* porque apresentam informações genéticas do ser humano enquanto espécie, sendo, nesse sentido, patrimônio da humanidade. São *estruturais* por guardarem características especiais de um indivíduo diferenciando-o dos outros, tornando-o singular. São *probabilísticos*

[27] A íris é a parte colorida dos nossos olhos, que circunda a pupila. Postula-se, atualmente, que a biometria seja feita não só através das impressões digitais – como já se faz, no Brasil, nas urnas eletrônicas e nos caixas eletrônicos dos bancos –, mas também através da íris. Aliás, o sistema ocular humano é tão magistralmente complexo que não cansa de fascinar os cientistas.

por apresentarem, de forma aproximada, as possibilidades do desenvolvimento de alguma enfermidade. E, por fim, são *geracionais* por informar a herança genética do indivíduo e a sua interligação genética com seus parentes"[28].

Importante nos parece fixar, como linha de tendência, que: a) deve ser proibida, no âmbito público ou privado (lembremos da eficácia horizontal dos direitos fundamentais), qualquer forma de discriminação de uma pessoa à luz de seu patrimônio genético[29]; e b) certos dados, de natureza médica e genética, não podem ser utilizados para fins negociais[30]. Não há dúvida, nesse sentido, que proteger certos dados genéticos é proteger a pessoa humana e sua dignidade, numa época de incríveis e admiráveis avanços científicos.

2.2. Bioética e autonomia do paciente

Já se disse a respeito da bioética, de modo um tanto amargo: "A bioética é a mais depressiva das especialidades filosóficas. Seus manuais são uma coleção de situações médicas trágicas que geram dilemas sem solução feliz. Se existe um princípio heurístico nessa triste disciplina, é o de que o respeito à autonomia do paciente e seus familiares é quase sempre a resposta menos ruim"[31]. A bioética não é, na verdade, uma ciência autônoma. É mais uma abordagem crítica, sob uma perspectiva ética, dos casos difíceis relacionados às ciências da saúde. Se, digamos, alguém está em coma sem chances de voltar à consciência, vale a pena continuar administrando os medicamentos que mantém artificialmente a vida? São questões como essa, sem soluções simples ou fáceis.

Aliás, o conceito atual de bioética não está limitado à medicina, mas engloba vários outros campos – o mais visível, por certo, é o da engenharia genética. As biotecnologias são uma marca deste século, que avança de modo espantoso no domínio científico.

É certo que a bioética tem um olhar fundamentalmente interdisciplinar, chamando vários e diferentes saberes para analisar as questões que se colocam[32]. Seja como for, a dignidade humana é vetor que ilumina as soluções. A autodeterminação e o consentimento informado desempenham, aqui, funções de especial relevo. O biodireito está tematicamente ligado à bioética, só que, nele, existe não apenas o olhar ético da bioética, mas há uma força específica que vem das normas jurídicas.

[28] SÁ, Maria de Fátima Freire; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira. *Manual de Biodireito*. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 190; Cf. HAMMERSCHMIDT, Denise. Alguns aspectos da informação, intimidade e discrição genética no âmbito jurídico internacional. *Revista dos Tribunais*. São Paulo, ano 94, v. 837, pp. 11-42, p. 17-20; BORSELINO, Patrizia. *Bioetica tra "morali" e diritto*. Milano: Raffaello Cortina, 2009.

[29] CASABONA, Carlos María Romeo. Protección jurídica del genoma humano en el derecho internacional: El Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y Biomedicina. In: CASABONA, Carlos María Romeo. *Genética y derecho*. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2001, p. 316.

[30] Cf. RODOTÁ, Stefano. *A vida na sociedade de vigilância. A privacidade hoje*. Organização e apresentação de Maria Celina Bodin de Moraes. Tradução de Danilo Doneda, Luciana Doneda e Caitlin Mulholland. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 3/10 e passim.

[31] SCHWARTSMAN, Hélio. Balbúrdia teológica. *Folha de São Paulo*. 16/08/2014.

[32] Conferir: SAUWEN, Regina Fiuza; HRYNIEXICZ, Severo. *O Direito "in vitro"*: da Bioética ao Biodireito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997. Também: GARRAFA, Volnei. *Introdução à bioética*: bioética e ciência – até onde avançar sem agredir. Brasília: Conselho Federal de Medicina, 1998.

O biodireito, portanto, é a dimensão jurídica da bioética. O biodireito teria como princípios: o princípio da precaução, o princípio da autonomia privada e o princípio da responsabilidade[33]. Também, por certo, a dignidade humana, que perpassa qualquer setor da experiência jurídica, sendo particularmente importante aqui.

2.2.1. A questão das Diretrizes Antecipadas de Vontade (DAVs)

As diretrizes antecipadas de vontade são instruções que alguém realiza, de modo prévio, com relação a cuidados e tratamentos médicos. É possível – sobretudo diante do doenças crônico-degenerativas – que no futuro não nos seja possível exprimir nossas vontades e expressar nossas decisões de modo autônomo. As DAVs existem para lidar com essa realidade, e evitar que se faça conosco algo que não gostaríamos que fosse feito (ou *não se faça* algo que gostaríamos que fosse feito). A questão é polêmica – aliás, *todos os temas* deste capítulo são polêmicos – e não é o caso de aprofundar a discussão nesta obra.

Cabe mencionar que o Conselho Federal de Medicina, através da Resolução n. 1995, de 2012, tratou das diretrizes antecipadas de vontade no Brasil. Embora não se trate de lei, não deixa de ser um (importante) elemento hermenêutico para ser usado em diálogo das fontes. O CFM resolve "Art. 1º. Definir diretivas antecipadas de vontade como o conjunto de desejos, prévia e expressamente manifestados pelo paciente, sobre cuidados e tratamentos que quer, ou não, receber no momento em que estiver incapacitado de expressar, livre e autonomamente, sua vontade". E continua: "Art. 2º. Nas decisões sobre cuidados e tratamentos de pacientes que se encontram incapazes de comunicar-se, ou de expressar de maneira livre e independente suas vontades, o médico levará em consideração suas diretivas antecipadas de vontade".

O Conselho Federal de Medicina aludiu, nos fundamentos da resolução, à "atual relevância da questão da autonomia do paciente no contexto da relação médico-paciente, bem como sua interface com as diretrizes antecipadas de vontade" e considerou ainda "que os novos recursos tecnológicos permitem a adoção de medidas desproporcionais que prolongam o sofrimento do paciente em estado terminal, sem trazer benefícios, e que essas medidas podem ter sido antecipadamente rejeitadas pelo mesmo". Enfim, através das diretrizes antecipadas de vontade defere-se à pessoa a liberdade de escrever a sua biografia, conforme seu conceito de qualidade de vida, ou seja, conforme sente e percebe as coisas[34].

[33] Confira-se, a propósito, *Manual de Biodireito*, de Maria de Fátima Freire de Sá e Bruno Torquato de Oliveira Naves (SÁ, Maria de Fátima Freire; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira. *Manual de Biodireito*. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 36-41). Os princípios elencados no texto são propostos pelos autores. Já a bioética, segundo os autores, teria como princípios a beneficência, autonomia e justiça.

[34] ROSENVALD, Nelson. Curatela. *Tratato de Direito das Famílias*. Belo Horizonte: IBDFAM, 2015, pp. 731-800, p. 791. Ainda: "As diretrizes antecipadas de vontade são instruções elaboradas por uma pessoa em relação a tratamentos médicos que deseja aceitar ou recusar, se num momento futuro se encontrar incapaz de exprimir e tomar as suas próprias decisões. Assim, no uso de uma *autonomia prospectiva*, designará uma ou mais pessoas para o *munus* de curador – também designado *procurador para cuidados de saúde* –, com instruções sobre as suas peculiaridades existenciais e patrimoniais, decidindo livremente sobre seu futuro". Portugal, em 2012, aprovou uma lei que regula as DAVs, após intenso debate na sociedade portuguesa. As DAVs, na lei portuguesa, podem assumir a forma de testamento vital e/ou procurador de cuidados de saúde.

2.3. Direito à morte digna? Distinguindo ortotanásia, distanásia, suicídio assistido e eutanásia

"Caridade, caridade
estrela de brilho infindo,
o que resta é vaidade,
que o tempo vai consumindo".

Chico Xavier

"Meu amigo Mario Cabral dizia que queria morrer ouvindo 'Jesus, Alegria dos Homens'; nunca soube se lhe fizeram a vontade. A mim, um lento ranger de porteira e seu baque final, como na fazenda do Frade, já me bastam. Ou então a batida desse velho relógio, que marcou a morte do meu pai e, vinte anos depois, a de minha mãe; e que eu morra às quatro e quarenta da manhã, com ele marcando cinco e batendo onze, não faz mal; até é capaz de me cair bem".

Rubem Braga

Os avanços da medicina, verdadeiramente incríveis, trouxeram óbvios benefícios à humanidade. A expectativa de vida aumentou de modo considerável e doenças que eram letais décadas ou séculos deixaram de ser. Há, porém, um curioso efeito colateral: esses mesmos avanços permitem, em muitos casos, adiar a morte por tempo considerável, mesmo com pouca ou nenhuma qualidade de vida do paciente. É nesse contexto que se insere a discussão do presente tópico.

A ortotanásia consiste em não prolongar um tratamento que não trará nenhum benefício real ao doente (nesse caso, não se *provoca* a morte, deixa-se que ela venha sem, porém, recorrer a prolongamentos excessivos diante do caso). Paulo Lôbo entende que "o direito à vida não inclui o direito à antecipação da morte no sistema jurídico brasileiro. Não se considera antecipação ou violação do direito à vida, a pretensão à morte natural, quando a vida é mantida artificialmente mediante o uso de equipamentos ou medicações"[35]. A ortotanásia pode ser objeto das diretrizes antecipadas de vontade (afinal de contas, trata-se da pretensão à morte natural, pretensão de não prolongar a vida de modo artificial).

Já a distanásia é o contrário, o oposto da ortotanásia. Na distanásia tenta-se por todas as formas prolongar a vida do paciente, mesmo que em estado vegetativo e sem nenhuma qualidade. No suicídio assistido, como a terminologia revela,

[35] LÔBO, Paulo. *Direito Civil. Parte Geral*. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 146. A imprensa relatou no final de 2017 um curioso caso: "Aconteceu nos EUA e o relato está em uma carta enviada por médicos e pesquisadores da Universidade de Miami à revista *New England Journal of Medicine*: um paciente de 70 anos foi levado para o hospital inconsciente após ter bebido demais. Ele tinha histórico de diabetes, doença pulmonar e arritmia. Até aí, nada tão fora do ordinário. Durante a recuperação, ele teve uma piora grave. Seu sangue estava muito ácido e sua pressão estava baixando – sem uma rápida intervenção, ele poderia morrer. A questão é que ele tinha uma tatuagem no peito na qual se lia: "*Do Not Resuscitate*", com *Not* sublinhado. (traduz-se como "*Não Ressuscitar*", em português). Logo abaixo, a possível assinatura do paciente. O paciente não foi identificado e nenhum membro da família o acompanhava" (*Folha de São Paulo*, 02/12/2017).

o próprio paciente é agente ativo de sua morte, ainda que eventualmente assistido por outrem. Em novembro de 2014, a americana Brittany Maynard, de 29 anos, que tinha câncer no cérebro em estágio terminal, morreu ao realizar um suicídio assistido. Por fim, na eutanásia – palavra de origem grega que remete à morte boa ou suave – diz respeito àquelas mortes provocadas por outrem, para livrar alguém de doença aflitiva e incurável. Não nos parece possível que as diretrizes antecipadas de vontade tenham por objeto o suicídio assistido ou a eutanásia. Já a ortotanásia, como dissemos antes, pode ser objeto das diretrizes antecipadas de vontade.

Um aspecto que deve ser frisado, em relação ao biodireito e à bioética, porém, é o progressivo respeito à autonomia e à autodeterminação dos pacientes[36]. Se o paciente não puder, de nenhuma forma, se manifestar, isso pode ser buscado e inferido por outros meios. Desse modo, "a pessoa chamada a decidir em lugar do incapaz tem o dever de levar em consideração desejos e sentimentos, crenças e valores nos quais a pessoa baseou a sua vida e que, no momento da decisão mais dramática, sobre o morrer, iluminam todo o seu itinerário existencial, atrelam a decisão a esta complexidade e não a ressecam na exclusividade burocrática de um ato formal. A lei alemã é igualmente explícita: "A vontade presumida será averiguada com base em elementos concretos. Devem ser considerados, em particular, declarações orais ou escritas feitas anteriormente pelo assistido, suas convicções éticas ou religiosas e eventuais outros valores de referência"[37].

2.4. Os novos modos de "engravidar" no século XXI

"Convém, a quem nasce, escolher muito bem o local, o ano e os pais".

Genaro Bufalino

Melhor que falar de morte é falar de vida. É o que faremos neste item.

O século XXI é um ciclo histórico iconoclasta em vários sentidos. Revoluciona, sem cerimônia, o sentido dos fatos, fazendo-os diferentes daquilo que costumavam ser. No dia, por exemplo, em que escrevemos este tópico, os jornais anunciam que um casal homoafetivo – que vive junto há décadas – conseguiu, finalmente, "engravidar". Com a ajuda de uma empresa israelense (fundada por um casal homoafetivo que teve que pagar 300 mil reais, nos EUA, para conseguir "engravidar"), forneceram o sêmen e escolheram, dentre várias mulheres que constavam no site da empresa, aquela que seria a doadora do óvulo. Já a gravidez propriamente dita ocorreria em outro país, na Tailândia, com mulheres que cobram para servir como barrigas de aluguel. No Brasil, o Ministério das Relações Exteriores emitiu documento afirmando

[36] Conferir: RÖHE, Anderson. *O paciente terminal e o direito de morrer*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. Em perspectiva mais ampla: BALDASSARRE, Antonio. *Diritti della persona e valori costituzionali*. Torino: Giapichelli, 1997; ALBANO, Lilian Maria José. *Biodireito*: os avanços da genética e seus efeitos ético-jurídicos. São Paulo: Atheneu, 2004.

[37] RODOTÀ, Stefano. *Perché laico*. Bari: Laterza, 2010, p.189-205.

que o procedimento cumpriu os trâmites legais exigidos. Um tempo depois, o casal voltava para Minas Gerais com as filhas (lindas gêmeas), aguardadas pela família há décadas.

Esse é só um exemplo de como os nossos dias surpreendem e espantam, em relação ao passado. Enfim, a ciência avança rápido – mais rápido, às vezes, que a nossa lenta capacidade de assimilar dos fatos. Cientistas britânicos anunciaram, em 2015, uma nova – e fabulosa – possibilidade: a fertilização com *duas* mães e um pai. O filho é formado com o DNA de três pessoas. O Parlamento britânico, depois de muita discussão, aprovou a técnica. A técnica evita que uma mulher com DNA mitocondrial defeituoso passe para o filho doenças congênitas, como cegueira e epilepsia.

Não é incomum, hoje, que a avó da criança que vai nascer empreste sua barriga para que a gestação lá ocorra, diante de alguma impossibilidade (médica) da mãe em fazê-lo. Há, nesses casos, um descompasso entre a mãe biológica (aquela que tem seu óvulo fecundado) e a mãe que empresta seu corpo para possibilitar que a gravidez se consume (aquela que fornece seu útero – fornecimento que, no Brasil, não pode ser remunerado, deve ser gratuito). Assim, entre nós, cada vez mais, mães, irmãs e até avós emprestam seus corpos para que a vida humana possa belamente se desenvolver no âmbito familiar, entre laços de solidariedade e afeto.

Convém sistematizar, ainda que brevemente, a questão da gestação em útero alheio no Brasil (*surrogate mother* ou outras tantas denominações possíveis: "maternidade por substituição", "cessão de útero" ou ainda "mãe por procuração"). Basicamente quatro pontos devem ser observados: a) como dissemos acima, precisa ser gratuito (a doação temporária de útero não poderá ser lucrativa); b) ambas as partes devem ser civilmente capazes; c) a "dona" do óvulo deve ter uma incapacidade gestacional, e isso precisa ser comprovado (não se pode, por exemplo, usar o procedimento para evitar uma gravidez com preocupações estéticas); d) a mulher que empresta sua barriga, seu útero (chamada mãe hospedeira) deve ser, em regra pessoa da família. Em casos excepcionais, admite-se outra mulher, exigindo-se autorização específica (a questão é tratada na Resolução n. 2.168 do Conselho Federal de Medicina, que prevê que a gestação de substituição – ou cessão temporária de útero – não poderá ter caráter lucrativo, como dissemos antes, e que a cedente temporária deve pertencer à família de um dos parceiros em parentesco consaguíneo até quarto grau, demais casos estarão sujeitos à autorização). Aliás, a resolução citada, de novembro de 2017, adota nova disciplina para uso das técnicas de reprodução assistida – buscando, em essência, o aperfeiçoamento das técnicas, com mais apurada segurança e eficácia dos tratamentos, e também respeito à bioética.

Há casos, por assim dizer, já "tradicionais". Casos que já não são novidade entre nós. São os casos de casais que apresentam dificuldades para ter filhos – estima-se que um a cada seis casais tenha dificuldades na questão – e, por isso, recorrem às possibilidades atuais da ciência. Que são basicamente duas: a) inseminação artificial; b) fertilização *in vitro* (antigamente chamada de "proveta"). No primeiro caso (inseminação artificial), o médico insere o material genético já fecundado no corpo da mulher, onde a gravidez, espera-se, se desenvolverá. No segundo caso (fertilização

in vitro), o médico retira os óvulos no corpo da mulher para fertilizá-los em laboratório. Em seguida, transfere os embriões resultantes para seu útero. Milhões de crianças, em todo o mundo, já nasceram dessa forma.

Ambas as formas mencionadas – inseminação artificial e fertilização *in vitro* – podem ser homóloga ou heteróloga. Na homóloga, o sêmen usado é do cônjuge ou companheiro. O Código Civil, a propósito, prevê, no art. 1.597: "Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos: III - havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido; IV - havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga". Na heteróloga, é de terceiro (geralmente, de um banco de sêmen). Nesse caso – cuja doação do sêmen será necessariamente gratuita – é necessária a autorização do cônjuge ou companheiro. O cônjuge ou companheiro, na hipótese, será o pai da criança (a aquiescência, no caso, equivale a uma adoção, se assim quisermos falar), o que significa dizer que estes não poderão, posteriormente, por óbvio, propor ação de investigação de paternidade ou mesmo negá-la.

O consentimento informado é fundamental para todos os pacientes submetidos à reprodução assistida. Não é permitida a seleção do sexo da criança (presença ou ausência do cromossomo Y). Também não é possível escolher qualquer outra característica biológica do futuro filho. A doação do material genético não pode ter fins lucrativos. Doadores e receptores, além disso, não devem se conhecer. É possível, até mesmo, que haja a reprodução assistida *post-mortem*, desde que haja autorização prévia e específica do falecido para uso do material biológico criopreservado.

Hoje, como vimos, o avanço científico soluciona, de modo notável, vários problemas de reprodução humana.

2.5. Um novo olhar para os riscos

Ao direito dos nossos dias – sobretudo em se tratando de direitos fundamentais – não se tolera a indiferença diante dos danos, mesmo que futuros ou potenciais. Cabe progressivamente construir uma tutela não só repressiva, mas fundamentalmente preventiva. Não é valorativa ou funcionalmente equivalente preservar determinado bem jurídico fundamental ou aceitar sua lesão em lugar de uma posterior e imperfeita indenização monetária. A linha de tendência linha hermenêutica, portanto, aponta para a proteção preventiva do bem, de todas as formas e de todos os modos possíveis. O princípio da proporcionalidade pode iluminar os contextos e orientar as soluções dos casos, nem sempre fáceis. Em relação a muitos dos danos do nosso século (pensemos, por exemplo, nos danos ambientais), podemos dizer que a complexidade que os abraça nem sempre se situa no domínio das causas visíveis. Há, em muitos casos, riscos invisíveis, que não podem ser prontamente detectados.

Lembremos, aliás, que atualmente o conceito de risco cada vez mais se aproxima da dimensão jurídica. O mero risco, em muitos setores da experiência jurídica, pode funcionar como mecanismo deflagrador do dever de proteção. A palavra de ordem é evitar danos.

Os princípios da precaução e da prevenção dialogam com a teoria do risco[38]. Busca-se, cada vez mais, o implemento de técnicas preventivas e precaucionais, para tratar diferentemente o diferente. Percebe-se a insuficiência dos emperrados instrumentos da racionalidade jurídica tradicional, liberal-individualística. Nem todos os riscos são iguais, e nem todos, por conseguinte, devem receber idêntico tratamento do direito. Por exemplo, o risco concreto (ou mesmo, em certos casos, potencial) encontra paralelo conceitual no princípio da prevenção. Ao passo que o risco abstrato é melhor trabalhado pelo princípio da precaução. Seja como for, o conceito de risco é juridicizado, ganha relevância conceitual específica no direito de danos do século XXI.

As sociedades, através dos tempos, em seus ciclos evolutivos, renovam suas percepções acerca de quais seriam os riscos aceitáveis. Os princípios da prevenção e da precaução são algumas das ferramentas jurídicas que nos auxiliam a lidar com essas situações, sempre historicamente mutáveis. Pontes de Miranda – escrevendo em meados do século passado – ensina que "o direito não só reage contra o ilícito; também reage contra atos e estados dos quais resulta ser possível ou provável a contrariedade a direito". E continua: "Sempre que o direito reputa evitável o perigo grave, permite preveni-lo. Preveni-lo quer dizer *prae-venire*, vir antes do fato lesivo; naturalmente, com algum ato que concorra para afastar o perigo, ou, pelo menos, precisar as consequências da contrariedade a direito. A tutela jurídica preventiva pode ser expediente de *técnica legislativa*, ou expediente de *técnica judiciária*"[39]. Lembra ainda o genial jurista que há espécies em que se previne a lesão futura após lesão já ocorrida. E argutamente pondera ser erro, e grave, ter-se a tutela judiciária preventiva como espécie de reparação de danos.

Hoje responsabiliza-se civilmente pessoas físicas e jurídicas pelos riscos de determinadas atividades. Por outro lado, diminuem os espaços em que o responsável pela atividade geradora de risco pode invocar com sucesso as excludentes de responsabilidade civil, porquanto atividade gera responsabilidade, se o dano está a ela vinculado. Em outras palavras o conceito de fortuito interno é refuncionalizado para proteger a vítima dos danos (um exemplo: se um hacker invade o computador

[38] Nessa ordem de ideias, "diante da nova estrutura da ilicitude civil, pode ser visto que a probabilidade determinante de um dano ambiental futuro (dano às futuras gerações) desvela-se como ilícito passível de sanção civil, imprimindo a possibilidade de imposição de restrições em razão dos seus custos sociais (Paollo Gallo)" (CARVALHO, Délton Winter de. *Dano ambiental futuro*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, p. 67). O autor menciona, ainda, de forma interessante, que a produção de riscos ambientais intoleráveis configura ilícito ambiental e viola um dever de preventividade objetiva imposto pela Constituição Federal no art. 225.

[39] PONTES DE MIRANDA. *Tratado de Direito Privado*. T. 2. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, p. 361-362. A tutela pode abranger tanto deveres negativos como positivos. Marinoni argumenta que "diante das normas que estabelecem deveres positivos para a proteção de determinados direitos fundamentais (por exemplo, o dever de instalar tecnologia para que seja evitada poluição), a tutela que impõe o cumprimento do dever legal mediante a imposição de fazer constitui tutela destinada a impedir o prosseguimento do ilícito e, assim, proteger o direito fundamental. Entender que a ordem positiva para o cumprimento de dever de fazer não constitui tutela inibitória é supor que essa só é cabível quando a norma estabelece dever negativo. É esquecer que a própria norma, em alguns casos, possui função preventiva e que a tutela jurisdicional destinada a dar-lhes atuação tem por fim dar tutela ao direito que a própria norma violada objetiva proteger" (MARINONI, Luiz Guilherme. *Tutela contra o ilícito*. São Paulo: RT, 2015, p. 70).

de um cliente bancário e furta a senha, transferindo o dinheiro para outra conta, o banco responde civilmente por isso, perfazendo fortuito interno e risco da atividade, de acordo com a Súmula 479 do STJ).

No direito ambiental, tanto o princípio da prevenção quanto o da precaução buscam prevenir. Nesse contexto, a tutela do bem difuso ambiental se dá de forma preferencialmente preventiva. Não há divergência possível quanto a esse ponto. Lembremos, ainda, a propósito, que não se admite a teoria do fato consumado no direito ambiental, nem seria possível, obviamente, que se cogitasse de direito adquirido à degradação (o STJ já determinou a demolição de hotel que ocupou irregularmente terreno de marinha; além disso, o fato de determinado imóvel estar situado em região ecologicamente degradada não exime o proprietário dos deveres com a preservação e conservação futuras). Em relação aos princípios da prevenção e da precaução, lembremos que a formulação teórica que orientou ambos os princípios sabe que os danos ambientais costumam ser graves e irreversíveis. A distinção entre ambos se dá em relação aos riscos que autorizam a intervenção. Enquanto o princípio da prevenção lida com riscos conhecidos, com perigos concretos, o princípio da precaução opera diante de perigos desconhecidos, embora prováveis. A precaução se volta, portanto, contra o perigo abstrato. O princípio da prevenção instrumentaliza-se (sobretudo) através de medidas acautelatórias que objetivam impedir a degradação ambiental. O melhor exemplo de prevenção talvez seja o estudo de impacto ambiental, previsto no art. 225 § 1º, IV, da Constituição Federal.

Já o princípio da precaução é mais ousado. Talvez, aliás, ele seja mais invocado do que realmente colocado em prática[40]. Percebe-se igualmente que o princípio da precaução ganha consenso quando se dirige aos nossos corações. Há, contudo, dissenso e debilidade quanto aos modos e formas de implementá-lo[41]. Seja como for, o princípio da precaução abandona o critério da certeza, e assume – como forma de proteger o meio ambiente – que o pior pode acontecer, cabendo ao suposto ofensor provar a inofensividade do empreendimento. Nesse contexto, decidiu-se que "o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva" (STJ, REsp 1.060.753). Assim, o mero risco de dano autoriza que sejam adotadas medidas prévias necessárias para evitar que o dano ocorra. Na verdade, trata-se de uma *precaução contra o risco*. A precaução pode atuar diante de um risco que inicialmente não era vislumbrado. Responde-se por dano vinculado a determinadas atividades, desde que provável ou apenas possível. O ofensor não pode se manter alheio à possibilidade desses danos ocorrerem.

[40] KISS, Alexandre. The rights and interests of future generations and the precautionary principle. *The precautionary principle and international law*: the challenge of implementation. Hague: Kluwer Law International, 1996, p. 27.

[41] LORENZETTI, Ricardo Luis. *Teoria Geral do Direito Ambiental*. Trad. Fábio Costa Morosini e Fernanda Nunes Barbosa. São Paulo: RT, 2010, p. 73/74; OST, François. *A natureza à margem da lei*: a ecologia à prova do direito. Lisboa: Instituto Piaget, 1998, p. 309. O princípio da precaução sugere que somos responsáveis não apenas pelo que sabemos ou deveríamos saber, mas também nos provoca com o dever de duvidar. Cf. LAVIEILLE, Jean-Marc. *Droit International de l'Environnment*. Paris: Ellipses, 1998.

3. O DIÁLOGO INTERGERACIONAL: OLHANDO PARA O FUTURO

> *"Mergulharei no mar, esse velho conhecido, e lá deixarei outras partes de mim. Vivemos assim, abandonando certos passados e construindo outros. Não sei bem, amigo mar, o que me espera. Estou sereno, estou calmo. Quero um pouco de sua força. Que o novo ciclo que se inicia tenha, quem sabe, um pouco desta dignidade: humilde, simples, eterna".*
>
> Felipe Braga Netto

O diálogo intergeracional está presente não apenas no direito ambiental, mas também, de modo intenso, no biodireito, que discute questões de justiça transgeracional, iluminada pela seguinte indagação: que tipo de humanidade vamos deixar para as futuras gerações?[42] Voltaremos, de modo incidental, ao tema, ao longo do texto. Gostaríamos apenas de pontuar que alguns juristas lembram que as futuras gerações humanas são consideradas sujeitos de direito, embora não sejam, propriamente, pessoas, no sentido do direito civil[43].

4. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL: POSSÍVEIS REPERCUSSÕES HERMENÊUTICAS

Estamos conscientes do profundo grau de polêmica que a matéria desperta – e da ausência de respostas prontas. Aliás, não é difícil perceber que, na sociedade contemporânea, altera-se não só a forma de solução de problemas – cada vez mais tópica e mais voltada para o caso concreto –, mas os próprios problemas e dilemas alteram-se constantemente[44]. Sabe-se que o STF, em conhecido julgado, decidiu em 2017 que o Estado deve indenizar preso em situação degradante. O STF, tradicionalmente, sempre reconheceu a responsabilidade do Estado pela integridade física e psíquica daqueles que estão sob sua custódia (tanto que STF e STJ impõem a responsabilidade civil do Estado até mesmo quando ocorre o suicídio do preso, em razão da inobservância do dever específico de proteção).

Porém, geralmente, em matéria de responsabilidade civil do Estado, isso somente gerava o dever de indenizar estatal quando houvesse morte do preso (não importando se a morte resultou de ação de agente do poder público – assassinato praticado por policial ou agente penitenciário – ou de outro preso). Em 2017, porém, o STF foi além: reconheceu a lesão aos direitos fundamentais dos presos, independentemente do evento morte. O só fato de estar cumprindo a pena em condições degradantes faria surgir o dever de indenizar do Estado.

[42] SAUWEN, Regina Fiuza; HRYNIEXICZ, Severo. *O Direito "in vitro"*: da Bioética ao Biodireito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997, p. 18.

[43] Cf. LÔBO, Paulo. *Direito Civil. Parte Geral*. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 107.

[44] VIEHWEG, Theodor. *Tópica e jurisprudência*. Brasília: Departamento de Imprensa Nacional, 1979, p. 38.

A indenização fixada, no caso, foi relativamente baixa (2 mil reais). Houve, porém, 3 votos (Luís Roberto Barroso, Luiz Fux e Celso de Mello), que entenderam que o correto seria, não a indenização em dinheiro em face da situação degradante, mas a redução dos dias de prisão de modo proporcional. Barroso argumentou: "Estariam as políticas públicas a perder duas vezes: as relativas aos presídios, em condições mais indesejadas, e as referentes à segurança pública, prejudicada pela soltura antecipada de condenados". Fux, em linha semelhante, ponderou: "A fixação de valores não será a solução mais eficiente e menos onerosa. Ela, será, a meu modo de ver, a mais onerosa e menos eficiente".

O Plenário do STF, para fins de repercussão geral, aprovou a seguinte tese: "Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento".

Há, porém, um dado de realidade que se imporá, cedo ou tarde: presos em situação degradante, no Brasil, lamentavelmente, são quase todos. Não por acaso o STF, um pouco antes, falou em "estado de coisas inconstitucional" relativamente à condição degradante das penitenciárias no Brasil. A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal registrou: "Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caracterizado como estado de coisas inconstitucional"[45] (STF, ADPF 347, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 09/09/2015).

Cuidaremos, adiante, de outro aspecto muito atual e com fortes reflexos na vida dos cidadãos brasileiros dos nossos dias: a violência urbana e o dever de indenizar do Estado. Em certos aspectos, talvez não seja despropositado falar em "estado de coisas inconstitucional" em relação aos danos causados pela violência urbana (e o desamparo jurídico das vítimas). Embora a segurança pública seja um direito fundamental social – e um claro dever estatal, talvez o dever mais claro a ser desempenhado pelo Estado em face de seus cidadãos – é, ou tem sido, um dever puramente retórico, vazio, despido de qualquer mínima consequência concreta.

[45] A respeito da aplicação dos direitos sociais importa fazer alusão à tese do *estado de coisas inconstitucional – ECI*. A tese tem origem em decisões prolatadas pela Corte Constitucional da Colômbia (como na *Sentencia de Unificación – SU* 559, de novembro de 1997, em que se tratou da violação de direitos previdenciários de professores), fundamentada na existência de uma generalizada violação, de forma contínua e sistemática, de direitos fundamentais, individuais e sociais, dentro de uma sociedade. Ou seja, é a constatação de uma *prática generalizada, difusa, de afrontas aos direitos fundamentais e sociais*, causando uma falta estrutural, com a intenção de permitir a criação de soluções estruturais para a grave situação, consistente em contínuas inconstitucionalidades praticadas contra populações vulneráveis, em face de falhas (omissões) do poder público.

4.1. A normatividade dos direitos fundamentais: levando direitos a sério

Obviamente, pela característica que marca este livro – o dever de brevidade –, não é o caso de discutir demoradamente cada um desses (difíceis) assuntos. Trata-se apenas de situar o leitor, com clareza e objetividade, para as relevantes dimensões que a matéria envolve.

Nossa (jovem) democracia constitucional precisa, talvez, refletir sobre os deveres de proteção dos cidadãos, a cargo do Estado[46]. A proteção dos direitos fundamentais, inclusive contra agressões não estatais, não pode permanecer em nível retórico. A segurança pública, por exemplo – e seus óbvios contornos estatais – não é uma promessa vazia a ser cumprida "se der". Aliás, costumamos esquecer, em nossas reflexões jurídicas, que segurança e saúde são direitos fundamentais sociais (certamente não são, entre nós, direitos levados a sério).

4.2. Um passo além da retórica: não é uma proteção "se der"

Em conexão com o que dissemos no item anterior, verifica-se que apenas muito raramente se nota raciocínios (sobretudo jurisprudenciais) que extraiam consequências normativas, vinculantes, desses direitos (em relação à saúde ainda é mais frequente, em relação à segurança pública é raríssimo). A segurança pública, aliás, é um dever tão claramente estatal que os cidadãos sequer possuem a capacidade de autotutela, o uso legítimo da força é monopólio estatal. A afirmação é particularmente verdadeira nos espaços públicos, mas não só neles. Seja como for, há, hoje, um cenário (algo espantoso) de Estado ausente, passivo, indiferente. Em relação à segurança pública, o Estado, em certas ocasiões, age como se tivesse desistido de enfrentar a violência, como se as coisas "fossem assim mesmo", como se a proteção coubesse a cada um dos cidadãos, entregues à própria sorte.

4.3. Quanto mais valioso o direito, mais aceitável é o ativismo judicial

Hoje é muito estudada a chamada dimensão objetiva dos direitos fundamentais, de modo que toda a atividade interpretativa-aplicativa se vê voltada à maior realização possível dos direitos fundamentais. Aliás, o agente público, hoje, está obrigado a sacrificar o mínimo de direitos fundamentais, e preservá-los ao máximo. Há, também, uma mudança de paradigma no direito administrativo, superando o tom autoritário que focava as análises teóricas nos poderes do administrador, passando-se, hoje, a estudar as matérias à luz dos direitos fundamentais do cidadão.

[46] Nesse contexto, "o Estado moderno não deve, como no passado, proteger o cidadão tão somente dos ladrões, assassinos e outros malfeitores, mas a sua tarefa de proteção ampliou-se consideravelmente. De fato as dependências e as interações cada vez maiores do ser humano conduziram não só à ampliação das possibilidades de comunicação mas também a uma ampliação dos perigos aos quais o homem está exposto. O Estado é então obrigado a assumir novas tarefas em matéria de proteção" (FLEINER-GERSTER, Thomas. *Teoria Geral do Estado*. Trad. Marlene Holzhausen. Revisão técnica Flávia Portella Puschel. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 594). Ver também: GRIMM, Dieter. A função protetiva do Estado. Trad. Eduardo Mendonça. *A Constitucionalização do Direito: fundamentos teóricos e aplicações específicas*. Cláudio Pereira de Souza e Daniel Sarmento (Orgs). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 160.

A ideia de democracia ganha uma dimensão ativa em vários campos normativos. Podemos até dizer que "a participação fiscalizatória direta configura direito fundamental, cuja concretização tende a melhor tutelar a ação do Estado, simultaneamente em termos éticos e de eficiência, qualificando o espaço público, dominado pela democracia meramente formal"[47]. Alguns autores, ainda hoje, no século XXI, falam em súditos e soberanos, para mencionar as relações entre o cidadão e o Estado. As expressões estão claramente superadas. O cidadão não é súdito, e o Estado não é soberano, no sentido de poder incontrastável que não admite controle.

O Judiciário assumiu funções que não tinha no passado. Fala-se em ativismo judicial, que seria uma atuação mais vigorosa do juiz, ingressando em áreas que antes eram fundamentalmente políticas. Especificamente em relação às políticas públicas, vários problemas surgem quando o juiz ingressa nessa esfera. A crítica mais conhecida diz que, agindo assim, ele fere o princípio da separação dos poderes. Sem falar que o juiz não foi eleito, não tem legitimidade democrática. A doutrina atual reconhece o problema: "Constitucionalismo significa, em essência, limitação do poder e supremacia da lei. Democracia traduz-se em soberania popular e governo da maioria. O Estado constitucional de direito gravita em torno da dignidade da pessoa humana e da centralidade dos direitos fundamentais, nos quais se incluem a liberdade, a igualdade, o mínimo existencial. E os três Poderes – Legislativo, Executivo e Judiciário – têm o dever de realizar os direitos fundamentais, na maior extensão possível, tendo como limite mínimo o núcleo essencial desses direitos".

Enfim, quanto mais valioso o direito, mais aceitável será o ativismo judicial[48].

4.4. Fazendo conexões teóricas entre direitos sociais e consequências vinculantes

Há, geralmente, um espantoso abismo entre os discursos jurídicos e a prática social. Isso não é novidade, mas cabe aos intérpretes, sobretudo no direito civil, não se limitarem a repetir antigas verdades – possivelmente elas talvez nem sejam mais verdades, talvez sejam outras as verdades atuais, as verdades dos nossos dias. Seja como for, é fundamental que saibamos fazer, a cada momento, as conexões teóricas entre os direitos sociais e consequências normativas vinculantes.

Vivemos no Estado dos direitos fundamentais e essa constatação deverá iluminar todos os setores do direito civil (os diálogos devem existir no direito de família, contratos, sucessões etc.). Na responsabilidade civil, por exemplo, o princípio da solidariedade social autoriza novas leituras do nexo causal (o nexo causal não é matemático, naturalístico, mas sim imputacional, valorativo). A noção de risco penetra na dimensão jurídica e o que era fortuito externo passa a ser, em muitas situações, fortuito interno (isto é, passa a ser um risco que responsabiliza o responsável pela atividade, ainda que o dano tenha sido praticado por terceiro. É o que ocorre, hoje,

[47] FREITAS, Juarez. A democracia como princípio jurídico. FERRAZ, Luciano; MOTTA, Fabrício. *Direito Público Moderno*. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 171.

[48] SARMENTO, Daniel. *Direitos Fundamentais e Relações Privadas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 166.

por exemplo, com as fraudes bancárias, em relação aos clientes). A propósito, o STJ, em 2018, entendeu que no caso em que houve cancelamento de voo e substituição por transporte por via terrestre, de ônibus, tendo havido assalto ao ônibus, não se aplica a excludente do fortuito externo, devendo a empresa aérea indenizar os passageiros (STJ, REsp 1.728.068).

4.4.1. Poderes públicos

As atividades e funções a cargo dos Estados contemporâneos são variadas e complexas. Abrangem uma multiplicidade de tarefas e preocupações que certamente não faziam parte daquelas existentes nos séculos passados. Por isso – mas não só por isso – as atribuições e os limites de cada um dos poderes são constantemente revistas e postas em prova, na dinâmica veloz dos casos concretos.

Já mencionamos que as funções do Estado, hoje, são no mínimo mais coloridas que as tradicionais funções absenteístas dos séculos passados. O Estado tem longo histórico como inimigo dos direitos fundamentais (que foram criados, sabemos, para fazer frente às violências e agressões estatais). Os direitos fundamentais seriam, nessa perspectiva, direitos de defesa em face do Estado, uma espécie de trincheira para exigir abstenções estatais. Hoje, porém, a situação é outra. Há uma dimensão ativa, no sentido de exigir que o Estado aja – eficaz e adequadamente – para proteger direitos fundamentais de violações de terceiros. Se na função ou dimensão passiva dos direitos fundamentais exigíamos abstenções do Estado, na função ou dimensão ativa exigimos ações dele. Atualmente, na dimensão positiva, o Estado deve mais: deve proteger os direitos fundamentais de agressões provindas de terceiros (nessa perspectiva, o Estado aparece como amigo, não inimigo, dos direitos fundamentais).

Talvez seja interessante trazer dois novos conceitos, ainda pouco conhecidos. Trata-se de algo que vem sendo discutido na atual teoria do processo (e com relevância para o direito em geral). São estes conceitos: a) *processo estrutural* e b) *processo de interesse público*. No primeiro, no processo estrutural (*structural litigation*), há intervenção em políticas públicas pelo Judiciário. Há a intervenção em determinada estrutura burocrática (isso quase sempre se dá através da elaboração de um plano aprovado pelo juiz que é implementado ao longo de anos). Nos Estados Unidos, o exemplo paradigmático de litígio estrutural é a dessegregação racial das escolas públicas, iniciada com o julgamento de *Bown v. Board of Education*. Já o segundo, o processo civil de interesse público (*public interest litigation*), "se volta para a transformação da esfera público-governamental: criação de direito novo ou de conduta estatal nova, pela via dos precedentes obrigatórios, do controle de constitucionalidade ou do processo coletivo, em favor de toda a sociedade". Edilson Vitorelli traz como exemplo do segundo caso o direito de que pessoas do mesmo sexo se casem, o que foi obtido pela via do controle abstrato de constitucionalidade. O autor lembra ainda que "a análise, no caso dos litígios complexos, se afasta significativamente do binômio lícito-ilícito e se aproxima, inevitavelmente, de considerações que dependem de

um aspecto apenas material, versar sobre direitos humanos), terá eficácia supralegal, pairando acima da legislação infraconstitucional, mas em nível inferior à norma constitucional, de modo a resguardar a soberania nacional.

5.1. Constitucionalização e convencionalização do direito civil

Com isso, é perfeitamente possível afirmar que as normas de Direito Civil têm de se submeter, além de ao natural (e imprescindível) *controle de constitucionalidade*, também a um *controle de convencionalidade*, devendo se adequar aos tratados e convenções internacionais que disponham sobre direitos humanos, mas não tendo sido submetidos às formalidades de aprovação para ter natureza de emenda constitucional.

Inaugura-se, assim, um movimento de *convencionalização do Direito Civil*, adequando-se e respeitando os direitos humanos – o que é a tônica das relações internacionais. É que as normas de Direito Civil – assim como o ordenamento jurídico como um todo – precisam se harmonizar, mantendo uma *compatibilidade vertical*, tanto com o Texto Constitucional, quanto com os tratados e convenções internacionais de direitos humanos. E, sendo assim, detectada uma eventual incompatibilidade da norma infraconstitucional com um tratado de direitos humanos, sobreleva a suspensão de sua eficácia, respeitando a própria especialidade da convenção[50].

Frise-se, reforçando a compreensão da matéria, que toda e qualquer norma infraconstitucional de Direito Civil precisa ser compreendida em harmonia (vinculação vertical) com a Constituição da República, primeiramente, e com os Tratados e Convenções Internacionais de Direitos Humanos, em seguida. Havendo tensão entre a norma infraconstitucional e a convenção internacional, retira-se a eficácia daquela, prestigiando a *eficácia supralegal*[51] *dos tratados internacionais que tratam de direitos humanos.*

Aliás, o melhor exemplo dessa influência supranacional no direito civil (*convencionalização do Direito Civil*) temos na revolução ocorrida na teoria das incapacidades. Conforme adiante veremos, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015) materializou, no plano normativo interno, determinações da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – conhecida como Convenção de Nova York (ratificada pelo Congresso Nacional através do Decreto Legislativo n. 186/2008).

[50] Essa conclusão foi abraçada pelo STF, nas decisões proferidas no Recurso Extraordinário n. 466.343/SP, com relatoria do Ministro Cezar Peluso, e no *Habeas Corpus* 87.585/TO, cujo relator foi o Ministro Marco Aurélio, julgados em 3 de dezembro de 2008 e publicados no *Informativo* 531. Em ambos os precedentes, o Pretório Excelso entendeu que o Pacto de *San José da Costa Rica* (Convenção Interamericana de Direitos Humanos, aprovada antes do advento da Emenda Constitucional nº 45) foi acolhido com *status* supralegal no ordenamento jurídico interno, pairando acima da legislação infraconstitucional, mas devendo respeitar, de qualquer sorte, a norma constitucional. Com isso, deliberou a Corte Maior que as proteções humanitárias contidas no citado Tratado estão posicionadas acima da norma do Código Civil, afastando a eficácia da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, inclusive, o Supremo Tribunal Federal revogou a Súmula 619, que afirmava: "A prisão do depositário judicial pode ser decretada no próprio processo em que se constituiu o encargo, independentemente da propositura de ação de depósito". Em sendo assim, *tornou-se descabida a prisão civil do infiel depositário no direito brasileiro, em razão do acolhimento do Pacto de San José da Costa Rica em sede infraconstitucional.* Aliás, demonstrando a força da compreensão jurisprudencial sobre a matéria, foi editada a Súmula Vinculante 25 pelo Supremo Tribunal Federal, vazada em termos claros: "É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito".

[51] Colhe-se do voto do Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do RE 466.343/SP, os seguintes fundamentos: "Parece mais consistente a interpretação que atribui a característica da *supralegalidade* aos tratados e convenções de direitos humanos. Essa tese pugna pelo argumento de que os tratados sobre direitos humanos seriam *infraconstitucionais*, porém, diante de seu caráter especial em relação aos demais atos normativos internacionais, também seriam dotados de um atributo de *supralegalidade*. Em outros termos, os tratados sobre direitos humanos não poderiam afrontar a supremacia da Constituição, mas teriam lugar especial reservado no ordenamento jurídico. Equipará-los à legislação ordinária seria subestimar o seu valor especial no contexto do sistema de proteção dos direitos da pessoa humana".

6. OS PRINCÍPIOS E A PONDERAÇÃO DE INTERESSES (TÉCNICA DE BALANCEAMENTO) APLICADA AO DIREITO CIVIL

A natural abertura e plasticidade das normas-princípios trazem consigo a possibilidade do estabelecimento de conflitos entre eles[52], quando de sua aplicação aos casos concretos. Os clássicos métodos hermenêuticos de solução de conflitos entre regras jurídicas (critério da especialidade, da anterioridade e da hierarquia) se mostram insuficientes para dirimir tais colisões principiológicas, em razão do elevado grau de abstração, generalidade e indeterminação de cada um dos princípios em conflito.[53] E nessa ambiência surge a *técnica de ponderação de interesses* para solucionar o entrechoque de diferentes normas-princípio, a partir de uma nova formulação.

Utilizando a ponderação de interesses, o STF, em 2016 – em julgamento acirrado –, terminou por reputar incompatível com a Constituição da República uma lei estadual do Ceará que regulamentava a prática das vaquejadas. Deliberou, assim, que "a obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância do disposto no inciso VII do art. 225 da Carta Federal, no que veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Discrepa da norma constitucional a denominada vaquejada" (STF, Pleno, ADIn 4983, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 06/10/2016). Cabe lembrar que em 2017 a Constituição Federal foi alterada para fazer constar no art. 225, § 7º: "Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos". A norma claramente resultou de uma resposta do Congresso Nacional às decisões do STF que consideraram a vaquejada uma prática cruel. O Brasil, com essa norma, vai na contramão das legislações mais atuais acerca do tema. Voltaremos ao tema adiante.

Nessa arquitetura, a técnica de ponderação de interesses é uma verdadeira *técnica de decisão*, utilizada quando há colisão de princípios, importando na superação à tradicional técnica de subsunção. No particular das relações privadas, como consequência

[52] Explica Daniel Sarmento que "longe de se limitar à normatização esquemática das relações entre cidadão e Estado, a Constituição de 1988 espraiou-se por uma miríade de assuntos, que vão da família à energia nuclear. Assim, é difícil que qualquer controvérsia relevante no direito brasileiro não envolva, direta ou indiretamente, o manejo de algum princípio ou valor constitucional. A ponderação de interesses assume, neste contexto, relevo fundamental, não apenas nos quadrantes do Direito Constitucional, como também em todas as demais disciplinas jurídicas" (SARMENTO, Daniel. *A ponderação de interesses na Constituição Federal*, op. cit., p. 23).

[53] A ponderação é uma técnica de decisão que se presta, portanto, para solucionar conflitos estabelecidos no caso concreto "que não puderam ser resolvidos pelos elementos clássicos da hermenêutica jurídica (semântico, lógico, histórico, sistemático ou teleológico) nem pela moderna hermenêutica constitucional", nas palavras de Ana Paula de Barcellos. "Alguns parâmetros normativos para a ponderação constitucional", op. cit., p. 117.

da constitucionalização das relações de Direito Civil e da natural exigência de uma interpretação conforme a Constituição, foi (e é) necessário desenvolver técnicas que possam operar multidirecionalmente, respeitando os diversos valores fundamentais presentes em cada conflito de interesses. Arrematando, cabe repetir, à exaustão, ser tarefa típica do jurista contemporâneo buscar a otimização dos interesses coliden-tes, almejando dar concretude ao valor máximo do ordenamento jurídico, que é a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).

7. A APLICAÇÃO DAS NORMAS-REGRAS E A EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE DE DERROTABILIDADE (SUPERABILIDADE OU *DEFESEABILITY*) NOS CASOS EXTREMOS

Ao lado da indiscutível relevância dos princípios para o sistema jurídico, impõe-se registrar a importância das *normas-regras*. Partindo da premissa de que *normas-princípios* e *normas-regras* são espécies do gênero *normas jurídicas*, é fácil perceber que o Direito Civil está plasmado de ambas as categorias normativas, cada uma delas com relevância própria e específica para a solução dos conflitos privados estabelecidos na sociedade.

Os princípios exigem ponderação (balanceamento) para o caso de colisão, quando há um eventual entrechoque de princípios de mesma hierarquia, ao passo que as regras são aplicáveis pelo sistema do "tudo ou nada" (*an all or nothing*), preconizado, de há muito, por Ronald Dworkin.[54] Em visão pragmática, sem pretensão exaustiva, as regras possuem grande adequação para os casos fáceis (*easy cases*), enquanto os princípios se mostram particularmente adequados para a solução dos casos difíceis (*hard cases*). A regra não perde o contato com os princípios que serviram para fun-damentá-la quando de sua edição: "Toda regra jurídica pode ser apresentada como o resultado de uma ponderação de princípios feita pelo legislador"[55].

Contudo, a *especificação* e a *determinabilidade da norma-regra* podem gerar inconveniências para a aplicação da norma jurídica. Isso porque *trazendo consigo soluções apriorísticas, as regras* (válidas e compatíveis com o sistema jurídico) *podem, eventual e episodicamente, se colocar em rota de colisão com os ideais almejados pelo sistema jurídico como um todo.*

Para esses raros casos (casos trágicos ou extremos) é preciso delinear uma base de compreensão: não se trata de uma regra inválida (inconstitucional) ou incompa-tível com o sistema; ao revés, ela é válida e, *in these*, aplicável ao caso. Contudo, o seu comando normativo é incompatível com os contornos concretos do caso – que transcenderam o resultado almejado pela regra quando de sua elaboração pelo legis-lador. Enfim, a rara ocorrência da situação concreta faz com que a regra se mostre incompatível com a hipótese. A explicação de Luís Roberto Barroso é clara: "Há

[54] Para maior aprofundamento, veja-se: ALEXY, Robert. *Teoria dos direitos fundamentais*, op. cit., p. 90-91.

[55] PECZENIK, Aleksander. Apud BUSTAMANTE, Thomas. "Princípios, regras e conflitos normativos: uma nota sobre a superabilidade das regras jurídicas e as decisões *contra legem*", op. cit., p. 157.

hipóteses em que a adoção do comportamento descrito pela regra violará gravemente o próprio fim que ela busca alcançar"[56]

Equivale a dizer: é possível uma decisão judicial individualizada e específica, *superando a norma regulatória*, para homenagear os valores existenciais do sistema jurídico (e que, em última análise, são perseguidos pelas próprias regras aludidas). É como se a norma-regra contivesse uma cláusula implícita em seu âmago, estabe-lecendo a sua obrigatória aplicação, "*a menos que*" uma situação extraordinária se concretizasse[57]. No direito inglês, já se encontram precedentes judiciais, admitindo, expressamente, a tese da superabilidade[58].

Entre nós, nota-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora sem utilizar a expressão *derrotabilidade*, já teve ensejo de admitir a superação episó-dica de uma norma regulatória, apresentando solução casuística específica em mais de uma situação[59]. Por evidente, a superabilidade das regras válidas diz respeito a situações imprevistas ou imprevisíveis quando da edição do enunciado normativo do seu texto. Ou seja, diante de um *extreme case*.

8. APLICAÇÃO DO DIREITO CIVIL E OS DESACORDOS MORAIS RAZOÁVEIS

Estabelecida a premente necessidade de interpretação do Direito Civil a partir das normas-regras e das normas-princípios, bem assim como o seu mecanismo de interpretação por meio da técnica de ponderação de interesses (quando necessário), é preciso advertir para a aplicação da norma nas hipóteses de *desacordos morais razoáveis*.

[56] BARROSO, Luís Roberto. *Interpretação e aplicação da Constituição*, op. cit., p. 356.

[57] HART, Herbert. *O conceito de direito*. Trad. A Ribeiro Mendes. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1986.

[58] No caso "R. vs National Insurance Commissioner ex p. O'Connor" (1981 All E. R., 770), uma viúva que foi condenada por homicídio culposo do marido não fez jus aos benefícios previdenciários deixados por ele, embora inexistisse na legislação de regência uma previsão expressa para a exclusão do benefício. No caso, criou-se uma solução para reconhecer que, embora a legislação aludisse, tão só, ao crime doloso, não se poderia "dar sustentação a direitos originados de ilícitos criminais praticados por seu titular (sem distinguir crimes dolosos ou culposos)". (BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. *Teoria do precedente judicial*: a justificação e a aplicação de regras jurisprudenciais, op. cit., p. 478).

[59] Numa delas, o STF permitiu o sequestro de verbas de um estado da Federação, sem preterição de preferência, em um caso anômalo. A fundamentação do *decisum* merece atenção: "O Supremo entende, de modo uniforme, que cabe o sequestro unicamente se houver preterição ao direito de preferência, o que não se verificou no caso destes autos. [...] Ocorre, no entanto, que a situação de fato de que nestes autos se cuida consubstancia uma exceção. Com efeito, estamos diante de uma situação singular, exceção, e como observa Carl Schmitt, as normas só valem para as situações normais. [...] A esta Corte, sempre que necessário, incumbe decidir regulando também essas situações de exceção. Ao fazê-lo, não se afasta do ordenamento, eis que aplica a norma à exceção, desaplicando-a, isto é, retirando da exceção. Permito-me, ademais, insistir em que ao interpretarmos/aplicarmos o direito – porque aí não há dois momentos dis-tintos, mas uma só operação – ao praticarmos essa única operação, isto é, ao interpretarmos/aplicarmos o direito não nos exercitamos no mundo das abstrações, porém trabalhamos com a materialidade mais substancial da realidade. Decidimos não sobre teses, teorias ou doutrinas, mas situações do mundo da vida. Não estamos aqui para prestar contas a Montesquieu ou a Kelsen, porém para vivificarmos o ordenamento, todo ele. Por isso, o tomamos na sua totalidade. Não somos meros leitores de seus textos – para o que nos bastaria a alfabetização – mas magistrados que produzem normas, tecendo e recompondo o próprio ordenamento" (STF, Pleno, Agr. Reg. Recl. 3034, Rel. Min. Sepúl-veda Pertence, DJ 27/10/2006). Noutro interessante caso, a Corte Excelsa, uma vez mais sem fazer expressa alusão à terminologia, utilizou da técnica da derrotabilidade das regras ao negar a desconstituição da lei estadual da Bahia que criou o Município de Luís Eduardo Magalhães, ao arrepio das regras constitucionais, por reconhecer a *força normativa dos fatos que terminaram por surpreender o sistema jurídico*. Confira-se: "Ao Supremo Tribunal Federal incumbe decidir regulando também essas situações de exceção. Não se afasta do ordenamento, ao fazê-lo, eis que aplica a norma à exceção desaplicando-a, isto é, retirando-a da exceção. Cumpre verificar o que menos compromete a força normativa futura da Constituição e sua função de estabilização" (STF, Pleno, ADIn 2240, Rel. Min. Eros Grau, DJ 03/08/2007).

Com efeito, na sociedade hipercomplexa em que vivemos, com uma multiplicidade de situações conflituosas e com diferentes interesses surgindo a cada momento, é natural que se estabeleçam conflitos jurídicos das mais diferentes índoles. Surgem os chamados *hard cases* (casos difíceis), para os quais a norma não previu uma solução apriorística, impondo a busca de um resultado a partir de atividade interpretativa. Invocando a lição de Ronald Dworkin, *hard cases* são aqueles não cobertos por uma regra clara e específica, a determinar a sua solução, ou seja, sem deixar claro como devem ser decididos[60].

Por conta de sua natureza e de suas peculiaridades, muitos desses conflitos apresentam um alto grau de moralidade subjacente, envolvendo aspectos muito pessoais, de conteúdo religioso, sexual, filosófico etc. Apresentam-se, nessa arquitetura, os chamados *desacordos morais razoáveis*. São aquelas matérias polêmicas, complexas, sobre questões emergentes ou persistentes, para as quais existe a possibilidade de admitir soluções antagônicas, diametralmente opostas, a partir de uma interpretação racional do próprio sistema jurídico. Ou seja, são posições divergentes inteiramente, porém constitucionalmente (juridicamente) legítimas, coexistindo no seio da sociedade.

Luís Roberto Barroso destaca que "no mundo contemporâneo, nas sociedades plurais e complexas em que nós vivemos, pessoas esclarecidas e bem intencionadas pensam de maneira diferente acerca de temas moralmente controvertidos. Não é difícil comprovar e ilustrar o argumento com situações envolvendo a) eutanásia e suicídio assistido; isto é, a existência ou não de um direito à morte digna; b) a questão da recusa de transfusão de sangue por pessoas adeptas da religião Testemunhas de Jeová; e c) o debate sobre a descriminalização das drogas leves"[61].

Para a solução de conflitos jurídicos, inclusive no campo do direito privado, somente é possível invocar os *desacordos morais razoáveis* quando existem valores constitucionais igualmente relevantes em conflito, a legitimar tanto uma tese favorável, quanto uma outra desfavorável. Não se pode tolerar a alegação de *desacordo moral razoável* para retirar de alguém o exercício de determinado direito fundamental ou interesse jurídico legítimo, por mais que aquela conduta seja repugnada pela maioria da sociedade. É o excelente exemplo da união familiar homoafetiva. Conquanto se trate uma posição minoritária, repugnada por setores específicos da sociedade, não se pode negar o exercício de direitos fundamentais.

Conquanto minoritárias, determinadas condutas e posturas precisam ser respeitadas, quando decorram do exercício de direitos fundamentais. Exige-se uma tolerância mínima em relação aos desacordos morais para viabilizar a vida digna em sociedade. Daniel Sarmento pondera que "aceitar e respeitar o outro na sua diferença, reconhecendo o seu direito de viver à sua maneira, é cada vez mais essencial no

[60] DWORKIN, Ronald. *Levando os direitos a sério*, op. cit., p. 127. Verticalizando um pouco mais, vem se emprestando a denominação para definir as situações para as quais "a dogmática não oferece solução unívoca imediata, dependendo de uma construção posterior, alicerçada em proposições que sejam juridicamente adequadas e admissíveis" (TAVARES, André Ramos. *Direito Constitucional brasileiro concretizado: hard cases* e soluções juridicamente adequadas, op. cit., p. 51).

[61] BARROSO, Luís Roberto. *O novo Direito Constitucional brasileiro*. op. cit., p. 37.

contexto da crescente diversidade cultural, étnica e religiosa que caracteriza a vida nas sociedades contemporâneas"[62].

9. A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LEI N. 13.709/2018)

Trata-se de relevante lei brasileira (LGPD), promulgada no segundo semestre de 2018 – seguindo as pegadas da legislação européia, cujo *Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais* (GDPR) foi aprovado em abril de 2016. Os estudos atuais enxergam a proteção das pessoas físicas, relativamente ao tratamento de seus dados pessoais, como direito fundamental. Na sociedade atual – marcadamente tecnológica e caracterizada por crescente economia digital – a proteção dos dados pessoais se mostra necessidade evidente. A lei brasileira trata de informações classificadas como pessoais por qualquer meio – seja por pessoas naturais, seja por pessoas jurídicas. Não é exagero dizer que, em múltiplos contextos, quem tem acesso aos dados tem poder. Trata-se de ativo fortemente valorizado nos dias atuais.

A LGPD tem perfil principiológico – como aliás é cada vez mais comum nas leis do século XXI. Busca fundamentalmente resguardar a privacidade dos titulares de dados. Aplica-se ao tratamento dos dados pessoais não só por pessoas (físicas ou jurídicas) privadas, mas também públicas. Tem como objetivo a proteção dos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos: o respeito à privacidade; a autodeterminação informativa; a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião; a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais.

A lei terá possivelmente significativo impacto no setor das *Startups* mas não só nele, também das grandes empresas e até do poder público. A LGPD – como é conhecida – terá alcance extraterritorial, aplicando-se a dados que sejam tratados fora do Brasil, "desde que a coleta tenha ocorrido em território nacional, ou por oferta de produto ou serviço para indivíduos no território nacional ou que estivessem no Brasil. Desse modo, o dado pessoal tratado por uma empresa de serviço de *cloud computing* que armazene o dado fora do país terá que cumprir as exigências da LGPD"[63]. Aliás, a matéria é melhor regulada através de tratados, já que os fluxos de dados, na sociedade digital, claramente não respeitam fronteiras entre países.

A LGPD é aplicável a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que:

[62] SARMENTO, Daniel. *Livres e iguais*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 243.

[63] PINHEIRO, Patricia Peck. *Proteção de Dados Pessoais. Comentários à Lei n. 13.709/2018 (LGPD)*. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 29. A autora, mais adiante, destaca: "Um ponto de atenção bastante relevante é retratado pelo art. 8º, que é a questão do consentimento. Ao longo dos anos, a necessidade do consentimento na coleta de dados, principalmente no ambiente virtual, foi ganhando importância em razão da sensibilidade e vulnerabilidade que as informações pessoais foram adquirindo com o desenvolvimento da tecnologia".

I – a operação de tratamento seja realizada no território nacional; II – a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional; III – os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional (LGPD, art. 3º).

O tratamento de dados pessoais somente poderá ser fundamentado em finalidades legítimas, consideradas a partir de situações concretas. O tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse (LGPD, art. 14). O tratamento de dados pessoais pelo poder público deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública e na busca do interesse público (LGPD, art. 23). O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo (LGPD, art. 42). O juiz, no processo civil, poderá inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados quando, a seu juízo, for verossímil a alegação, houver hipossuficiência para fins de produção de prova ou quando a produção de prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa (LGPD, art. 42, § 2º). As ações de reparação por danos coletivos que tenham por objeto a responsabilização podem ser exercidas coletivamente em juízo, observado o disposto na legislação pertinente (LGPD, art. 42, § 3º). A LGPD prevê o caráter solidário da responsabilização do controlador e do operador.

Não cabe, por certo, nos limites deste livro, uma análise específica de cada uma das dimensões da referida lei. Cabe-nos apenas uma palavra breve acerca do sentido de sua inserção no contexto geral das relações civis. Reproduziremos, nos próximos parágrafos, o que escrevemos em outra oportunidade, apenas para sinalizar o sentido social das mudanças.

A internet – que surgiu como uma forma de interligação, de modo descentralizado, dos computadores militares americanos – passou a ser utilizada comercialmente nos Estados Unidos em 1987. Foi então que ganhou essa denominação, internet. No Brasil, a internet chegou em meados da década de noventa (em 1995, especificamente, é publicada uma norma do Ministério das Comunicações que marca esse início). A internet, sob o prisma técnico, é a conexão entre protocolos, conhecidos como IPs (*internet protocol*). Esse IP, uma espécie de endereço digital, permite que as investigações descubram (ou tentem descobrir) de onde partiram certas postagens na rede. Há, ainda, os nomes de domínio (*domain name system*), que são os endereços que digitamos para chegar aos sites, complementados pelas respectivas terminações (*top level domains*), que são os finais dos endereços, após o ponto (ou o último ponto, se houver mais de um: *.com, .gov, .jus*). Nós nos deslocamos pela internet usando navegadores (*browsers*). Não por acaso, usamos o verbo navegar.

Talvez nem possamos mais dizer que a internet é uma rede mundial de computadores. Os computadores, hoje, são apenas mais um modo de conexão. Ninguém imaginava, há poucos anos que o computador pudesse estar em plano secundário. É o que parece ocorrer atualmente. Celulares e *tablets* assumem funções que antes eram só dos computadores. Em 2013 – pela primeira vez no Brasil – o número de *tablets* vendidos superou o de computadores. Temos, atualmente, e cada vez mais,

celulares, televisões, carros, casas e eletrodomésticos conectados à internet. Muitos de nós não podem sequer conceber a ideia de ficar dias – horas ou minutos, no caso dos mais ávidos – desconectados. Alguns, com evidente exagero, comparam o vício digital a certas drogas, como o crack.

Muitas relações, que antes se davam no mundo físico, agora são predominantemente virtuais. Por exemplo, as relações entre clientes e bancos migraram, em boa parte, do mundo físico-convencional para o mundo digital. Os serviços, aliás, em geral, migraram fortemente para o mundo digital. Vivemos numa sociedade em que os bens físicos perdem muito da primazia que tiveram nos séculos passados. Há uma clara desmaterialização dos bens (a riqueza, que nos séculos passados esteve indissoluvelmente ligada à terra, hoje está no mercado acionário). Paralelamente, os serviços ganham intensa, e progressiva, relevância econômica. Nossas profissões surgem a cada dia – ligadas, por exemplo, à culinária, à moda e, sobretudo, ao mundo digital –, e muitas delas são financeiramente mais atrativas do que aquelas convencionais. Talvez não exageraríamos se disséssemos que muitos pais, hoje, não conseguem compreender bem o trabalho dos filhos (gerente de mídias sociais, por exemplo). Enfim, podemos dizer, em autêntico truísmo, que o mundo mudou, está mudando. A tecnologia reduz custos operacionais dos deslocamentos, interliga pessoas e comunidades, diminui o uso de papel e a necessidade de estocagem física de documentos. As gerações que cresceram e foram educadas longe do mundo digital não se sentem confortáveis com essa "fuga do papel", digamos assim (*paper less society*). Há, nessas pessoas, um apego, até emocional, ao papel, ao documento escrito (como se isso as deixassem mais seguras). Mas a desmaterialização é uma tendência irreversível, gostemos ou não.

Nesse contexto, conforme frisamos, nota-se uma progressiva desmaterialização dos bens. Não só a forma de aquisição é digital (pedimos, por exemplo, táxis e pizzas pela internet), como os próprios serviços se desmaterializam (pensemos, por exemplo, num *e-book*. Não há bem físico palpável, nos moldes do mundo físico-convencional). Precisamos cada vez menos dos arquivos físicos. A progressiva desmaterialização de processos judiciais, documentos, arquivos, é – mais do que uma tendência – uma realidade que se impõe[64]. As duplicatas virtuais, por exemplo, são aceitas pela jurisprudência brasileira mais recente (STJ, AgRg no AREsp 3634; AgRg no AREsp 121.263). Os documentos passam a ter outros suportes que não o papel. Podemos levar, no bolso, num *pen drive*, informações correspondentes a muitas centenas de

[64] O STJ, em 2018, por maioria, reconheceu um contrato de mútuo celebrado e assinado eletronicamente como título executivo extrajudicial (STJ, REsp 1.495.920). O curioso é que não houve a assinatura de duas testemunhas, tal como exige o CPC para que o título seja passível de execução: "Possibilidade de excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos especiais requisitos, em face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual. Nem o Código Civil, nem o Código de Processo Civil, inclusive o de 2015, mostraram-se permeáveis à realidade negocial vigente e, especialmente, à revolução tecnológica que tem sido vivida no que toca aos modernos meios de celebração de negócios, que deixaram de se servir unicamente do papel, passando a se consubstanciar em meio eletrônico. A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados. Em face destes novos instrumentos de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante, possível o reconhecimento da executividade dos contratos eletrônicos".

livros. E mesmo o *pen drive*, conquanto prático e fisicamente mínimo, ainda precisa de uma base física, por assim dizer. A tendência, porém, é que tenhamos nossos arquivos nas "nuvens", acessíveis de qualquer lugar em que estejamos.

Estamos diante de um novo ambiente dimensional, que é influenciado pelo ambiente físico tradicional, mas por certo não se confunde com ele. Com frequência ocorre o contrário: o mundo digital influencia fortemente o ambiente social físico tradicional. Não há, na verdade, como separar os dois ambientes atualmente, sendo indissoluvelmente ligados. Aliás, a internet não apenas reproduz, com extrema velocidade, os fatos que acontecem no mundo físico-convencional. Ela *cria* novos fatos. As empresas e os governos, em especial, estão sujeitos a manifestações digitais, com repúdio e ataques diante desse ou daquele modo de agir. Podemos citar, de modo breve, sem pretensão de exaustividade, algumas das características da internet: a) transnacionalidade por excelência; b) potencial de compartilhamento das informações inédito na história humana; c) velocidade das trocas de informações; d) conteúdo fortemente colaborativo. As três primeiras características são de intuitiva compreensão. A internet não conhece as barreiras que separam os países. Permite compartilhar informações de um modo que a humanidade antes desconhecia. E tudo isso ocorre com velocidade estonteante. São pontos que todos nós, de um modo ou de outro, conhecemos. A última característica é formar uma dimensão fundamentalmente colaborativa.

Usufruímos, hoje, da chamada "memória social", que é aquela acessada instantaneamente por meio da tecnologia. Segundo Clive Thompson, "as ferramentas tecnológicas não nos isolam, é o oposto. Temos nos tornado pensadores mais sociais. Temos mais oportunidades de dividir o que pensamos o tempo todo" (*Folha de São Paulo*, segunda-feira, 4/11/2013, F6). Enfim, trata-se, sem exagero, de um mundo novo. Um admirável mundo novo, com o qual estamos aprendendo a lidar – menos, ressalte-se, os que já nasceram ou cresceram nesse mundo novo, esses lidam com desconcertante naturalidade com o mundo digital que é, afinal de contas, o mundo dele (fala-se, a propósito, com propriedade, de *nativos digitais*. São aqueles que estão em contato com a internet desde que nasceram, ao contrário daqueles que tiveram que se adaptar a ela[65].

Altera-se, de modo inesperado e poderoso, não só o modo de difusão das informações, mas também sua produção. Não falamos, aqui, da produção editada e empresarialmente concebida, nem mesmo aquelas que operam no mundo digital (jornais digitais e provedores com conteúdo informativo). Falamos da produção de conteúdo e informação por parte dos cidadãos. Nitidamente, opera-se um deslocamento dos centros de produção de informação: não mais estruturas centralizadas e, de certo modo, autoritárias, mas cadeias de comunicação reciprocamente conectadas, que trocam dados numa velocidade incrível. O *twitter*, por exemplo, é bastante forte nesse sentido. Aliás, os membros do universo digital compartilham experiências, históricas, e tendem a resolver problemas de modo compartilhado. Gostemos ou não, essa é a realidade do século XXI na qual viveremos. Isso, porém, inegavelmente, traz riscos. Com eles também viveremos.

[65] PRENSKY, Marc. *Digital Natives, Digital Immigrants*. From on the horizon – NCB University Press, v. 9, nº 5, oct., 2001.

3

PERSONALIDADE CIVIL

1. PERSONALIDADE: UM CONCEITO CHAVE PARA O DIREITO CIVIL

"Fé na vida, fé no homem, fé no que virá.
Nós podemos tudo, nós podemos mais.
Vamos lá fazer o que será".

Gonzaguinha

Personalidade é um conceito chave, não só para o direito civil, mas para os ramos do direito em geral. A pessoa é o polo possível das relações de direito[1]. Em regra, apenas quem ostenta personalidade pode ser sujeito de direito, isto é, ser titular de direitos e deveres. O Código Civil inicia seus 2.046 artigos reconhecendo, no art. 1º, que "toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil". Melhor andaria o Código Civil, no entanto, se ao invés de dizer que "toda pessoa é capaz", dissesse que "toda pessoa é titular de direitos e deveres na ordem civil", evitando assim confusões desnecessárias entre personalidade e capacidade. O Código Civil atual, em correta correção de rumos, alude à "pessoa", ao contrário do Código Civil de 1916, que preferia mencionar "homem".

As relações jurídicas se estabelecem, em linha de princípio, entre pessoas. Em seu esquematismo formal básico, a relação jurídica se perfaz entre, pelo menos, duas pessoas, tendo por objeto uma coisa. Se, por exemplo, Caio vende seu telefone celular para Beatriz, teremos, no caso, dois sujeitos de direito (Caio e Beatriz), numa relação jurídica diante de um objeto de direito (no caso, o celular). Todas as

[1] PONTES DE MIRANDA. *Tratado de Direito Privado*. T. I. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, p. 128.

pessoas físicas, sem distinção possível, têm capacidade de direito. Capacidade de direito (capacidade jurídica) é conceito que se confunde com o de personalidade, reconhecendo em alguém a condição de protagonista de relações jurídicas. Não existe ser humano sem capacidade de direito. A personalidade é um conceito qualitativo, que não admite graus[2]. Já a capacidade, que adiante veremos, admite graus, pode ser mais ou menos intensa. O conceito de sujeito de direito, como adiante veremos, é mais amplo que o de pessoa, abrangendo, por exemplo, o espólio ou o condomínio edilício, que são sujeitos de direito (podem ser parte numa relação processual), porém não são pessoas[3].

As pessoas são as protagonistas do mundo jurídico. O conceito não é caracterizado pelo discernimento (quem não tem discernimento é pessoa), nem pela vontade (quem não tem vontade válida é pessoa) nem por qualquer outro caractere subjetivo ou objetivo (quem possui deficiências, mesmo as mais dolorosas e desfigurantes, é pessoa. Aliás, como veremos no próximo capítulo, a partir da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e, no plano interno, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2015, deixou de existir a categoria dos absolutamente incapazes por ausência de discernimento. Em outras palavras, a deficiência não afeta a plena capacidade civil das pessoas). Mas, antes de abordar a questão da capacidade, é fundamental, neste capítulo, abordar a questão da pessoa humana. Hoje o conceito está intimamente atrelado à dignidade. O ordenamento reconhece em cada ser humano não só uma pessoa, mas uma pessoa dotada de específica dignidade. Esse vetor, mais do que um arroubo retórico, é um vetor normativo forte e denso, que repercute nas mais diversas soluções concretas.

Dizer, hoje, que a pessoa é um centro de imputação de direitos e deveres é correto, mas insuficiente. A pessoa, sim, é isso, mas é mais – muito mais – que isso. Há camadas éticas, substantivas, espirituais, no conceito de pessoa. O direito dos nossos dias não é mais o direito do século XIX, abstrato e formal, mas procura, em suas soluções, enxergar a pessoa como um ser humano concreto, no aqui e no agora, com seus projetos de vida, suas dores e dificuldades, suas escolhas existenciais mais importantes. A pessoa é um vasto universo de contradições e possibilidades. O ser humano, aliás, sabemos, é emocionalmente complexo. Capaz de belos atos de bondade e renúncia, e terríveis agressões molhadas de egoísmo e crueldade. Como escreveu Machado de Assis, o coração humano é a região do inesperado.

[2] FERNANDES, Luís Carvalho. *Teoria geral do direito civil*. v. 1. Lisboa: Universidade Católica, 2007, 128

[3] Cf. MELLO, Marcos Bernardes de. *Teoria do Fato Jurídico. Plano da Existência*. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 104, menciona: "Há mais entes juridicamente capazes do que pessoas"; MELLO, Marcos Bernardes de. *Teoria do Fato Jurídico. Plano da Eficácia*. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 144: "Ser sujeito de direito, portanto, é ser titular de relação jurídica, seja como termo de relação jurídica, seja como detentor de uma simples posição no mundo jurídico"; LÔBO, Paulo. *Curso de Direito Civil. Parte Geral*. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 103, sublinha que "o conceito de sujeito de direito é mais abrangente, sem necessidade de expansão do significado de pessoa, com risco de sua descaracterização". Em relação ao exemplo dado no texto – no sentido de que o condomínio *não é* pessoa – convém lembrar que a matéria é doutrinariamente polêmica. As *Jornadas de Direito Civil*, através do Enunciado 246, concluíram: "Deve ser reconhecida personalidade jurídica ao condomínio edilício".

2. QUANDO TEM INÍCIO A PERSONALIDADE?

> *"À bela princesa Andréa de Azulay, você precisa saber que já é uma escritora. Mas nem ligue, faça de conta que nem é. Escreva sobre ovo que dá certo. Dá certo também escrever sobre estrela. E sobre a quentura que os bichos dão à gente. Cerque-se da proteção divina e humana, tenha sempre pai e mãe – escreva o que quiser sem ligar para ninguém. Você me entendeu?".*
>
> (Clarice Lispector em carta para Andréa de Azulay, então uma criança).

Grandes polêmicas rasgam os séculos no que se refere ao início da personalidade humana. Seria a partir do nascimento com vida? Seria antes? Há relevância prática, ou apenas filosófica e conceitual, na diferenciação? A discussão, nos últimos tempos, ganhou maior complexidade com os embriões, que podem estar fora do útero materno – algo inconcebível no passado. Seja como for, uma das grandes discussões teóricas do direito civil é esta: o nascituro é pessoa?[4].

Deixemos, porém, desde já um ponto claro (que talvez, de tão óbvio, nem precisasse ser mencionado): se há dúvidas e acesas polêmicas acerca do início da personalidade humana, não há, atualmente, em nosso estágio evolutivo, nenhuma dúvida de que *todo* ser humano que tenha nascido com vida é pessoa. Já estamos felizmente longe da época em que se *coisificava* e se *instrumentalizava* o ser humano como coisa, como escravo (se bem que só podemos afirmar isso, ainda no século XXI, em certos contextos culturais. Basta lembrar, na Índia, o deplorável sistema de castas e a brutal situação da mulher em certas sociedades no Oriente Médio). Em nosso sistema jurídico, quem nasceu com vida é pessoa e tem a nota da dignidade humana (que traduz um vetor normativo que obriga todos os demais a tratá-lo com dignidade). Irrelevante que a vida extrauterina seja ou não viável (mesmo porque os médicos frequentemente se enganam quanto a isso: muitas vezes o que não parecia possível aos olhos da medicina acaba acontecendo). Irrelevante, também, do mesmo modo, que haja essa ou aquela deficiência, por mais inusual ou horrenda que possa ser. Talvez nesses casos, mais do que em quaisquer outros, estejamos sendo testados em nossa humanidade, em nossa capacidade de doação e mesmo em nosso amor. Cada vez mais, no século XXI, o homem perceberá a relevância dos aspectos não puramente físicos em sua evolução.

Lembremos, ainda, embora talvez de modo desnecessário, que o registro civil da pessoa física é puramente declaratório e não, por certo, constitutivo (autores de renome no direito tributário defendiam, espantosamente, a tese do caráter constitutivo do registro da pessoa física, escancaradamente contrária à nossa Constituição e a todos os tratados internacionais, além de contrariar os valores e as legítimas expectativas sociais). Chegava-se a dizer que o suporte fático da norma do homicídio (Código Penal, art. 121), não se configurava, se a vítima não fosse civilmente

[4] Ver, sobre o tema, AMARAL, Francisco. O nascituro no direito civil brasileiro: contribuição do direito português. *Revista Brasileira de Direito Comparado*. Rio de Janeiro, 1990, n. 8, pp. 75-89.

registrada (não seria, argumentava-se, "alguém", para o direito)[5]. Cremos que o argumento sequer merece resposta. Melhor talvez nem pensar quantos seres humanos, sobretudo mais humildes, nas "vastas solidões" do Brasil, não seriam considerados pessoas porque não teriam tido a oportunidade do registro civil de nascimento. O direito civil do século XXI é, em tudo e por tudo, o mais distante oposto do que essa posição representa. O registro de nascimento da criança, sendo declaratório, tem eficácia *ex tunc*, e apenas reconhece uma realidade preexistente. Em relação às pessoas jurídicas, como adiante veremos, o registro é constitutivo, faz nascer uma nova realidade que inexistia antes do registro. Convém lembrar que a Constituição de 1988 garante a gratuidade do registro de nascimento e da certidão de óbito para os reconhecidamente pobres, na forma da lei (CF, art. 5º, LXXVI e Lei n. 9.534/97).

2.1. A questão do nascituro: três teorias explicativas

Denomina-se, geralmente, feto ao nascituro a partir da oitava semana de gravidez. No direito, porém, geralmente usamos o termo nascituro para o ser concebido mas que ainda não nasceu, não importando a fase ou estágio da gravidez. José Jairo Gomes esclarece que "nascituro é o nome dado ao ser humano já concebido, mas que ainda não nasceu, encontrando-se em desenvolvimento no útero materno. Em outros termos, o nascituro é o produto da concepção visto em qualquer das fases assinaladas, isto é, considerado como ovo, embrião ou feto. Trata-se de *pessoa humana em formação*, e, como tal, deve ter respeitada a dignidade que lhe é inerente"[6].

A matéria, contudo, não é pacífica. Pelo contrário. O padrão mental tradicional ainda reluta em aceitar o nascituro como pessoa. É o que veremos nos próximos itens.

Pontes de Miranda lembra que o problema de ter nascido com vida o ser humano é questão de fato, não é questão de direito. Há de ser resolvido com os recursos da ciência do momento[7]. Qualquer sinal, ainda que mínimo, de vida, há de ser considerado como tal. Sob o prisma patrimonial, se o feto não nascer com vida, não receberá nem transmitirá herança ou doação (embora tenha tido seus interesses físico-existenciais protegidos enquanto viveu no útero). Hoje devem ser vislumbrados não só os direitos e interesses patrimoniais que giram em torno do nascituro, mas também – e sobretudo – aqueles existenciais (não deixa de ser curioso notar que grande parte da discussão, através dos séculos, indagando se a criança nasceu ou não com vida, preocupava-se apenas com direitos patrimoniais).

[5] Assim, defendendo essa postura, argumenta-se que "*a constituição jurídica desse fato (do nascimento) vai ocorrer quando os pais ou responsáveis comparecem ao cartório de registro civil e prestarem declarações*. O oficial do cartório expedirá a norma jurídica, em que o antecedente é o fato jurídico do nascimento, na conformidade das declarações prestadas, e o consequente é a prescrição de relações jurídicas em que o recém-nascido aparece como titular de direitos fundamentais" (CARVALHO, Paulo de Barros. *Direito tributário*: fundamentos jurídicos da incidência. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 89).

[6] GOMES, José Jairo. *Teoria Geral do Direito Civil*. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 48.

[7] Há códigos civis, como o espanhol, que exigiam determinado tempo de vida (24 horas fora do ventre materno, no caso do espanhol, art. 30). O Código Civil espanhol, no entanto, foi alterado em 2011, em razão das críticas que recebia, e passou a afirmar que a personalidade se adquire no momento do nascimento com vida. Já o Código Civil argentino exige sinais de vida, como a respiração, estabelecendo, porém presunção *juris tantum* a favor do nascimento com vida. Quem alega que não houve vida, deve provar.

2.1.1. Teoria concepcionista

Para os autores que perfilham tal teoria, o marco inicial da personificação do ser humano é a concepção – antes, portanto, do nascimento com vida. Notáveis juristas como Teixeira de Freitas, Pontes de Miranda, Francisco Amaral, Antônio Junqueira de Azevedo, Silmara Chinelato, entre outros, defendem que a partir da concepção já temos uma pessoa, que como tal deve ser protegida. É, também, a nossa posição, o nosso modo – há tempos – de sentir e perceber o problema. A propósito, o biólogo Botella Lluziá lembra que o embrião traduz um ser individualizado, com carga genética própria – não se confundindo, em absoluto, com a carga genética do pai ou da mãe[8]. Aliás, Teixeira de Freitas, no seu genial *Esboço do Código Civil* – que tanto influenciou os códigos civis nascidos no século XX – denominava o nascituro, apropriadamente, de "pessoa por nascer". Considerava-o pessoa, portanto. O Pacto de São José da Costa Rica, no art. 4.1, estabelece que "toda pessoa tem direito a que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido por lei, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente".

Considerar, hoje, o nascituro *coisa* seria fazer pouco caso da dignidade humana, do próprio caminhar ético-cultural da espécie humana. Estamos, é verdade, diante de um estágio especial de desenvolvimento – pelo qual todos nós passamos – e que só assim os fortes afetos e sólidos amores se corporificam e enchem de sentido a trajetória de cada um de nós. Há, portanto, para o nascituro, o *direito de nascer*, direito-base para todos os demais, uma espécie – com o perdão do trocadilho – de direito-mãe, para o nascituro. O tempo de gestação aparece, para certas análises, como fator relevante. A proteção civil-constitucional, nesse sentido, seria tanto maior quanto mais avançada estivesse a gravidez[9]. Cremos que o nascituro em qualquer estágio da gravidez é pessoa.

2.1.1.1. O nascituro como pessoa em estágio peculiar de desenvolvimento

O nascituro, no contexto anteriormente descrito, seria *pessoa em formação, pessoa num estágio peculiar e próprio de desenvolvimento*. Há, na doutrina, cada vez mais, quem perfilhe de semelhante entendimento: "Segundo pensamos, o nascituro tem personalidade desde a concepção. Apenas certos efeitos de certos direitos, ou seja, os patrimoniais materiais, dependem do nascimento com vida, como o direito de receber doação e de receber herança. Os direitos absolutos da personalidade, como o direito à vida, o direito à integridade física e à saúde, independem do nascimento"[10]. Nesse sentido, se o pai falecer, estando grávida a mulher, deverá ser nomeado curador para o nascituro, se a mulher não tiver o poder familiar (Código Civil, art. 1.779).

[8] ESTAL, Gabriel Del. *Derecho a la vida e institución familiar*. Madrid: Eapsa, 1979. Prólogo escrito por Botella Lluziá.

[9] Cf. CASABONA, Carlos María Romeo. *El Derecho y la Bioetica ante los Limites de la Vida Humana*. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 1994, pp. 142-161.

[10] ALMEIDA, Silmara Chinelato. O nascituro no Código Civil e no direito constituendo do Brasil. *Revista de Informação Legislativa*, n. 97. Brasília, v. 25, 1988. Na linha do que escrevemos a seguir, convém lembrar que "os direitos de natureza patrimonial (apreciáveis economicamente), como a doação, a herança, o legado e a pensão previdenciária,

Não só isso: o STJ já reconheceu dano moral ao nascituro (STJ, REsp 1.487.089, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T, DJ 28/10/2015) no conhecido caso do humorista Rafinha Bastos *x* Wanessa Camargo (a questão do nascituro foi explicitada no acórdão do TJ/SP). Muito antes disso o STJ já afirmara que "o nascituro também tem direito aos danos morais pela morte do pai" (STJ, REsp 399.028, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª T, DJ 15/04/2002). No plano legislativo, nossa legislação admite os chamados "alimentos gravídicos", que são aqueles concedidos à gestante, em favor do nascituro, da concepção até o parto. O nascituro, assim, tem direito aos alimentos. O direito civil dos nossos dias trabalha intensamente com a categoria conceitual da vulnerabilidade. Se isso se aplica a nós, adultos (pensemos nos consumidores), aplica-se sobretudo aos idosos, às crianças, aqueles enfim que se mostrem mais frágeis por esse ou aquele motivo (são aqueles a quem chamamos, hoje, de hipervulneráveis). Aplica-se, também, com muito maior razão, aos nascituros, cujas vidas estão em nossas mãos.

2.1.1.2. Nascituro: direitos existenciais x direitos patrimoniais

Talvez seja interessante distinguir, em relação ao nascituro, os direitos existenciais dos direitos patrimoniais. Segundo essa visão, o nascituro *é* pessoa, e como tal goza dos direitos existenciais desde que concebido. O Código Penal criminaliza o aborto (arts. 124 a 127)[11]. Tem, como dissemos, o direito de nascer, que é o direito mais importante no seu peculiar estágio de desenvolvimento. A esse direito estão intimamente ligados o direito à saúde, à integridade física, à dignidade humana etc. Seria, por exemplo, agressor da dignidade humana um experimento científico, ainda que realizado com a anuência da mãe, que privasse o nascituro desse ou daquele nutriente para fins de estudo ou pesquisa. Sob o ângulo patrimonial, a doação feita ao nascituro valerá, se aceita por seu representante legal (Código Civil, art. 542); o nascituro pode ver-se representado por curador no caso de conflito de interesses com a mãe ou mesmo diante da incapacidade dela; pode ser legatário; pode ser parte em ação judicial (como autor em ação de alimentos e em ação de investigação de paternidade, e réu em ação anulatória de testamento ou de contrato de doação que o contemple). Lembremos, ainda, da ação de alimentos, no caso da mãe não poder prover à própria subsistência (a sua e a do filho em formação). Daí, pode-se perguntar: como não lhe atribuir personalidade?

somente serão adquiridos pelo nascituro com o implemento do nascimento com vida, uma vez que a plenitude da eficácia desses direitos patrimoniais fica condicionada a esse evento futuro e incerto (nascimento com vida). Exemplificando, se é doado um imóvel a um nascituro, enquanto ele não nascer com vida, não poderá ser promovido o registro regular no cartório de imóveis em seu nome. Todavia, se alguém pagou os tributos devidos, poderá cobrar do nascituro, se nasceu" (FARIAS, Cristiano Chaves de. A Família Parental. *Tratado de Direito das Famílias*. Belo Horizonte: IBDFAM, 2015, pp. 247-273, p. 261).

[11] Há, para Dworkin, certa confusão conceitual no debate sobre o aborto. Ele pondera que o ponto central da discussão não seria eventuais direitos do feto, mas o que chama de "caráter sagrado da vida", à luz das concepções dos religiosos ou dos liberais (Conferir: DWORKIN, Ronald. *O domínio da vida*. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2003). Convém lembrar que o STF, em 2016, por sua primeira turma, entendeu que a interrupção da gestação até o terceiro mês de gravidez não configura aborto.

2.1.2. Teoria natalista

Já para os adeptos da teoria natalista, o marco inicial da personificação é, não a concepção, mas apenas o nascimento com vida. O Código Civil, se interpretado literalmente, parece preferir esta segunda hipótese. Personalidade, portanto, para ele, apenas aqueles que nasceram com vida possuem. Mesmo entre os defensores da teoria natalista – que entende que só se é pessoa com o nascimento com vida – há posições teoricamente refinadas. Sílvio Rodrigues, por exemplo, entende que o nascituro não é pessoa, só havendo personalidade civil a partir do nascimento com vida[12]. Registre-se, nesse sentido, que mesmo os que ainda não foram concebidos – a chamada prole eventual (Código Civil, art. 1.798) – podem ser beneficiada por testamento (poderia, nesse sentido, ser entendida como sujeito de direito, porém não como pessoa). De modo semelhante decidiu-se: "Não tem o nascituro somente expectativas de direitos, sendo, no tocante aos direitos da personalidade, de forma efetiva, sujeito de direito. Todos os fatos relacionados à sua vida (direito de personalidade), desde o momento da concepção, geram consequências jurídicas"[13].

A teoria ou doutrina natalista exige, para que tenhamos uma pessoa física, a presença simultânea de dois requisitos: a) o nascimento; b) e que este nascimento tenha sido com vida. Se não houve ainda nascimento, não há pessoa, pois o nascituro, para a teoria natalista, não é pessoa. Se houver o nascimento (no sentido de saída do feto do corpo feminino), mas sem vida, tampouco estivemos diante de uma pessoa. A teoria natalista é a mais tradicional, a mais antiga, mesmo porque corporifica, de modo óbvio, uma nova realidade para os sentidos humanos: há um ser, provavelmente chorando, diante dos nossos olhos, ouvidos e mãos.

2.1.3. Teoria da personalidade condicional

Cabe ainda mencionar a doutrina da personalidade condicional. Washington de Barros Monteiro, a propósito, argumenta: "O nascituro é pessoa condicional, a aquisição da personalidade acha-se sob a dependência de condição suspensiva, o nascimento com vida"[14]. Essa postura teórica, em geral, é criticada e não vem

[12] RODRIGUES, Sílvio. *Direito* Civil: Direito de Família. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 36. Também: WALD, Arnoldo. *Curso de Direito Civil brasileiro*. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 118; RÁO, Vicente. *O direito e a vida dos direitos*. São Paulo: RT, 1999. Paulo Lôbo e Marcos Ehrhardt perfilham caminho um pouco diferente. Entendem que o nascituro não é pessoa, mas sujeito de direito. Assim, nessa visão, "pessoa é o ser humano nascido com vida; nascituro é o ser humano não nascido e que ainda está no ventre materno. Ambos são sujeitos de direito, a primeira personalizada e o segundo não personalizado". LÔBO, Paulo. *Direito Civil. Parte Geral*. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 103 e 107. No mesmo sentido: EHRHARDT JR, Marcos. *Direito Civil*. v. 1. Salvador: Juspodivm, 2009, p. 113.

[13] TJRS, Ap. Cível . 700.1034.5999, *apud* SÁ, Maria de Fátima Freire; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira. *Manual de Biodireito*. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 70. Conferir sobre o tema: PUIGELIER, Catherine. O estatuto jurídico do embrião e do feto. *Revista Trimestral de Direito Civil*. Rio de Janeiro: Padma, n. 26, abr./jun. 2006.

[14] MONTEIRO, Washington de Barros. *Curso de Direito Civil*: Direito de Família. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 67. Pontes de Miranda insurge-se, de modo veemente, contra essa teoria. Argumenta ser "de repelir-se qualquer noção de condição. Não há condição nas situações jurídicas do nascituro. (...). Entre presumir-se que nasça morto e presumir-se que nasça vivo, tudo – cálculo de probabilidade, política legislativa, equidade – aconselha a ter-se por mais provável o nascimento com vida. Se erramos, isto é, se nasce morto o concebido, demonstrado ficou que não havia, do lado passivo, quem recebesse a herança. Se o concebido nasce vivo, demonstrado ficou que havia pessoa, e essa se inseriu em toda relação jurídica que se constituíra" (PONTES DE MIRANDA. *Tratado de Direito Privado*. T. I. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, p. 179).

O Código Civil não diz que estão resguardados os direitos do embrião, mas do nascituro. No Brasil, o descarte do embrião pré-implantado não perfaz crime. É crime, contudo, a clonagem humana (11.105/2005, art. 6º, IV). O STF, como frisamos no capítulo dos direitos da personalidade, ao julgar a ADI n. 3.510, entendeu válida a norma que permite, para fins de terapia e pesquisa, a utilização de células-tronco embrionárias produzidas por fertilização *in vitro*. Seja como for, a verdade é que a natureza jurídica do embrião antes da implantação no útero materno ainda estar por ser definida pelos juristas (e não só por eles). A Constituição Suíça inovou ao mencionar, em 1992, a "dignidade da criatura". A proteção é dirigida fundamentalmente às questões envolvendo engenharia genética.

3.2. A situação do embrião depois da implantação no útero

Percebemos, no tópico passado, o tom polêmico da matéria, que não comporta unidade de vistas[22]. Aqui, porém, a questão é mais clara. O embrião depois de implantado no útero materno recebe a mesma proteção do nascituro, devendo ser resguardada, de modo generoso e intenso, sua integridade físico-existencial.

3.3. A decisão do STF sobre as células-tronco embrionárias

Discute-se, nas últimas décadas, com acesas polêmicas, a questão do uso científico e terapêutico das células-tronco embrionárias. O embrião é pessoa? Ou é um aglomerado de células que pode beneficiar (imensamente) pessoas que hoje estão vivas e doentes? O STF foi chamado a se pronunciar sobre o tema, em decisão precedida por audiência pública. Questionava-se, na ação, a Lei n. 11.105/2005 – a chamada Lei de Biossegurança – que permitia, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização *in vitro*. A lei exigia ainda, em seu art. 5º, que os embriões fossem inviáveis ou estivessem congelados há 3 anos ou mais. Necessário, também, segundo a lei, o consentimento dos genitores. Lembremos que as células-tronco embrionárias são células pluripotentes, podendo se transformar em qualquer outro tipo de célula, o que abre fabulosas perspectivas para a medicina.

O STF, em 2008, por maioria, julgou improcedente a referida ação (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.510-0). Manteve, portanto, a lei. Embora as argumentações dos votos tenham sido bastante distintas, pode-se dizer, em geral, que seguiu-se

seguranças). Supõe-se que o ex-médico implantava os embriões em outras mulheres, já que permitia que os casais escolhessem praticamente todas as características físicas das crianças que nasceriam, como num supermercado.

[22] Essa complexidade e essa pluralidade de opiniões parece fazer parte da experiência jurídica deste século. Assim, "pessoas razoáveis podem discordar – e de fato frequentemente discordam – sobre o que significa aplicar uma norma com esta estrutura num determinado caso. Veja-se, por exemplo, o debate atual sobre as pesquisas em células-tronco, em que o princípio da dignidade da pessoa humana é usado para fundamentar as posições dois lados – dos que afirmam que a autorização das pesquisas é inconstitucional, porque viola a dignidade dos pré-embriões que são objeto da investigação científica, e dos que defendem que ela é absolutamente legítima, para promover a dignidade dos doentes que poderão ser tratados e curados exatamente em razão dos resultados das pesquisas" (Daniel Sarmento. Ubiquidade constitucional: os dois lados da moeda. In: *A Constitucionalização do Direito: fundamentos teóricos e aplicações específicas*. Cláudio Pereira de Souza e Daniel Sarmento (Orgs). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 129/130).

– pelo menos a maioria do tribunal – a orientação do relator, Carlos Ayres, de que para existir vida humana é necessário que o embrião tenha sido implantado no útero humano. O embrião, antes disso, não seria pessoa, nem nascituro. Argumentou-se, ademais, que o uso científico e terapêutico das células-tronco aponta relevante função social ligada à saúde e a própria dignidade humanas. O Ministro Celso de Mello consignou: "O luminoso voto proferido pelo eminente Ministro Carlos Britto permitirá a esses milhões de brasileiros que hoje sofrem e que hoje se acham postos à margem da vida, o exercício concreto de um direito básico e inalienável que é o direito à busca da felicidade e também o direito de viver com dignidade, direito de que ninguém, absolutamente ninguém, pode ser privado". Hoje, portanto, é possível o uso dos embriões excedentes em pesquisas e terapias genéricas.

Conforme dissemos anteriormente, a questão – mesmo depois da decisão do STF – não é pacífica. Há quem entenda que os embriões são, sim, seres humanos, mesmo antes de implantados no útero materno. Assim, "os embriões são seres humanos em desenvolvimento que surgem depois de realizada a doação de sêmen ou óvulos, ou da entrega de matéria genético pelos contratantes ao depositário, resultantes da fecundação das células masculina e feminina, constituindo-se em um novo ser humano, não mais sendo apenas células germinativas"[23]. Um dos votos vencidos no STF, do Ministro Menezes Direito, argumentava que "as células-tronco embrionárias são vida humana e qualquer destinação delas à finalidade diversa que a reprodução humana viola o direito à vida". Trata-se, porém, de posição minoritária.

4. O CONCEITO CONTEMPORÂNEO DE PERSONALIDADE: UM CONCEITO ÉTICO-JURÍDICO

Já mencionamos o ponto anteriormente. A experiência jurídica do século XXI é fundamentalmente ético-jurídica. Não faz sentido, hoje, falar em direito como um repositório de soluções neutras e formais. Não é isso que a sociedade legitimamente espera, nem é isso que a Constituição de 88 – de índole transformadora e humanista – no caso brasileiro, determina. O conceito atual de personalidade não é puramente formal. Não basta dizer que pessoa é aquele que pode ser sujeito de direito. Continua sendo isso, mas *não é só isso*. Essencial às notas contemporâneas do conceito é a noção de dignidade humana. A exigência da racionalidade *não faz parte* do conceito atual de personalidade. Bem longe estamos disso.

Mesmo crianças que ainda não falam, por exemplo, são pessoas, ninguém ousaria negar. Igualmente, crianças ou adultos com doenças mentais graves – sem nenhum discernimento – são, também, por certo, pessoas, detentoras de igual dignidade (sobretudo nos nossos dias, quando a teoria das incapacidades foi adequada à Constituição Federal). Não cabe, portanto, sob esse argumento, negar a personalidade do nascituro. Também, por certo, pessoas que estão, em graus variados, privadas da racionalidade (por, pensemos, severas doenças mentais), ainda assim podem sofrer

[23] SZANIAWSKI, Elimar. O embrião excedente – o primado do direito à vida e de nascer. Análise do art. 9º do Projeto de Lei do Senado n. 90/99. *Revista Trimestral de Direito Civil*. Rio de Janeiro, ano 2. v. 8, pp. 83-107, out./dez. 2001, p. 102.

dano moral. A capacidade de entender a lesão sofrida não é requisito da configuração do dever de indenizar na hipótese. A dignidade humana é que o é (registre-se: não deixa de ser tristemente desconcertante falarmos em dignidade humana, em pleno século XXI, ao mesmo tempo em que os jornais exibem assustadores espetáculos de cabeças sendo decepadas à faca por radicais religiosos – com crianças obrigadas pelos fanáticos a assistir às cenas macabras).

5. UM NOVO OLHAR PARA OS ANIMAIS?

> *"Na escola primária a gente aprende que o cão é o melhor amigo do homem, que é inteligente e leal. Na escola secundária, a gente lê com muita emoção o "Fiel", de Guerra Junqueiro. Mas só se aprende a amar verdadeiramente os cães muito mais tarde, em plena escola da vida, quando se começa a conhecer melhor os homens".*
>
> Rubem Braga

> *"Houve, certamente, lá em casa, outros cães. (...). Não sei onde Valente ganhou esse belo nome. Deve ter sido literatura de algum Braga; pois hei de confessar que só o vi valente no comer angu. (...). Nesse ponto, e só nele, era o Valente um bom Braga; que de seu natural não é povo caçador; menos eu, que ando por este mundo a caçar ventos e melancolias".*
>
> Rubem Braga

A teoria geral do direito sempre separou claramente as pessoas das coisas. As pessoas seriam sujeitos de direito. As coisas, objeto de direito. Hoje, porém, talvez essa separação – tão rigorosa e rígida – não satisfaça à complexidade dos nossos dias. Aliás, os dualismos (lícito/ilícito; direito público/direito privado) estão sendo cada vez mais questionados, pelo menos como categorias opostas que se pretendem exclusivas na descrição de certas realidades[24]. As classificações duais, dessa forma, têm poder explicativo limitado, por apresentar uma simplificação exagerada de uma realidade complexa e fragmentada.

[24] Nesse sentido, em artigo publicado há 18 anos, escrevemos: "De fato, porque demasiadamente simplificadores, os dualismos (lícito/ilícito; bem/mal; branco/negro; privado/público) sempre exerceram sedução sobre os teóricos do direito, uma vez que se bipartia uma realidade por vezes matizada em duas categorias opostas e irredutíveis e, dessa forma, como que se resolvia tudo. Porém, tal saída parece estar, a cada dia, mais insustentável como solução teórica. A sociedade, avançando em velocidade espantosa, transpondo, em poucas décadas, barreiras culturais e tecnológicas que existiam há séculos, não mais se oferece como um *objeto* a ser assepticamente dividido em duas categorias opostas e conclusivas. É necessário que se reduza a abstração dos raciocínios, concretizando os argumentos, pois o excesso de conceitualismo, mormente na área jurídica, aliado ao conservadorismo inteligente dos juristas, tende a manter antigas e ultrapassadas categorias, com mudanças muitas vezes apenas cosméticas, quando a realidade já não autoriza tão lento modificar (BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Os sistemas duais e sua crise: o fim das grandes certezas. *Direitos e Deveres*. Maceió: Edufal, v. 2, n. 5, p. 115-132, jul./dez.1999). Em sentido semelhante, embora analisando outro tema: "A aproximação da autonomia da vontade à feição do mercado inspirou o clássico regime das incapacidades, uma refinada construção metafísica materializada por Savigny, capaz de cancelar a realidade fragmentária e conflituosa da vida pela artificialidade de conceitos técnicos, legitimando sobre o viés jurídico as dicotomias do juízo entre o certo/errado e o bem/mal" (ROSENVALD, Nelson. Curatela. *Tratato de Direito das Famílias*. Belo Horizonte: IBDFAM, 2015, pp. 731-800, p. 733).

Não se aceita, atualmente, que os animais sejam equiparados aos demais bens – como uma cadeira, um carro, ou mesmo como os minerais, por exemplo. Essa era a visão da doutrina clássica. Hoje até mesmo quem adota uma postura antropocêntrica – aquela que põe o ser humano sempre no centro das discussões – reconhece que os animais devem ser tratados de modo não cruel e que devem receber cuidados diferenciados. O bem estar dos animais passa a ser item relevante da pauta. Seja como for, reconhecer que os seres da natureza ostentam um *status* próprio, peculiar e diferenciado, não significa reconhecer-lhes como sujeitos de direito, apenas que não podemos, indistintamente, *coisificar* a natureza, de modo insensível e desconforme com os avanços científicos mais recentes.

Talvez uma das maiores referências, a respeito, seja o filósofo australiano Peter Singer. Professor de bioética, defende que o postulado essencial, na filosofia moral, não é a capacidade de pensar ou se comunicar, mas a de sofrer. Nessa perspectiva, basta que um ser possa sentir dor para que ele seja – ou deva ser – considerado em questões morais. Reduzir o sofrimento de seres que sentem dor é, portanto, uma questão moral relevante[25].

Herman Benjamin, a propósito do tema, pondera: "Esse conjunto de inovações constitucionais, substantivas e formais, mais cedo ou mais tarde haverá de levar, no plano mais amplo da Teoria Geral do Direito, a uma nova estrutura jurídica de regência das pessoas e dos bens. Da autonomia jurídica do meio ambiente decorre um regime próprio de tutela, já não centrado nos componentes do meio ambiente como coisas; muito ao contrário, trata-se de um conjunto aberto de direitos e obrigações, de caráter relacional, que, como acima referido, é verdadeira ordem pública ambiental, nascida em berço constitucional"[26].

Trata-se de linha de tendência a ser observada pelo estudioso. Não cremos, no entanto, que já estejamos lá. Aliás, Pontes de Miranda, o mais genial jurista que tivemos, já percebia que a Teoria Geral do Direito, em seus ciclos históricos, objetiva e subjetiva diferentemente as posições das pessoas e coisas, atendendo àquilo que parece mais razoável em determinado espaço-tempo histórico. Assim, "nos tempos

[25] SINGER, Peter. *Libertação animal*. Trad. Fátima St. Aubyn. Porto: Via Óptima, 2008; *Ética Prática*. Trad. Álvaro Augusto Fernandes. Lisboa: Gradiva, 2000. Há, porém, nos livros citados, posições absolutamente indefensáveis – como sustentar que os pais de bebês com deficiência poderiam decidir, junto com os médicos, se a vida da criança deveria continuar – diante dos valores previstos em nossa Constituição, que privilegiam fortemente a dignidade humana e a solidariedade social. Trata-se de algo tão repulsivo e distante das opções valorativas básicas de nossa Constituição que nem se precisa, no ponto, de exaustão argumentativa em sentido contrário.

[26] BENJAMIN, Herman. *Direito Constitucional Ambiental Brasileiro*. CANOTILHO, J.J. Gomes; LEITE, José Rubens Morato. *Direito Constitucional Ambiental Brasileiro*. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 36. Admite-se ainda a possibilidade do chamado *dano ecológico puro* ou *stricto sensu*, que seria aquele que a vítima não é apenas o ser humano, mas a *própria natureza*, autonomamente considerada (BENJAMIN, Herman V., Responsabilidade civil pelo dano ambiental. *Revista de Direito Ambiental*. São Paulo, v. 3, n. 9, p. 5-52, jan./mar. 1998, p. 39). O dano ambiental, nessa perspectiva, prescinde da referibilidade direta a alguém, como ofendido.

em que se admitiram coisas e animais como sujeitos de direito, nem por essa, para nós, hoje, estranha concepção, se deformava o direito: as regras jurídicas é que, incidindo, determinavam as subjetivações e objetivações"[27].

A *Folha de São Paulo*, em editorial de 08 de abril de 2017, destacou: "Os macacos superiores (gorilas, orangotangos e chimpanzés) estão no fulcro de um raciocínio que esfumaça a fronteira, outrora nítida, entre pessoas (sujeitos de direito) e animais (tratados como objeto). Inteligência, uso de ferramentas, rudimentos de linguagem e outras capacidades vêm sendo reveladas e descritas pela ciência também em outras ordens animais, como elefantes, golfinhos e até gralhas. É diante dos símios, porém, que vários humanos se curvam às evidências de similaridade – e delas extraem consequências jurídicas". Continua o jornal: "Argumenta-se que macacos deveriam gozar ao menos alguns direitos atribuídos a pessoas, como o de não ser privado de liberdade. Tal foi o fundamento da decisão do Judiciário argentino. As ações são movidas por grupos adeptos da doutrina ética difundida pelo filósofo australiano Peter Singer, autor do best-seller *Libertação Animal* (1975). Noutros países, contudo, as iniciativas judiciárias têm esbarrado na resistência de magistrados".

5.1. Há dignidade para além do ser humano?

A pergunta, porém, persiste: existe dignidade para além do ser humano? Em outras palavras: dignidade está limitada à vida humana? Poderíamos, ao contrário, ampliar seu espectro de incidência para outras formas de vida? Isso estaria de acordo com a nossa Constituição?[28]

5.1.1. Duas visões teóricas

Há quem, em postura antropocêntrica, responda negativamente, afirmando que o direito é voltado para a satisfação das necessidades humanas[29], consignando que a Constituição de 1988 adotou posição "explicitamente antropocêntrica". Isso, contudo, não é pacífico. Outros, porém, argumentam, que assim como se fala em dignidade da pessoa humana, atribuindo-se valor intrínseco à vida humana, também parece possível conceber a dignidade da vida em geral. Diz-se que "se a dignidade consiste em um valor próprio e distintivo que nós atribuímos a determinada manifestação

[27] PONTES DE MIRANDA. *Tratado de Direito Privado*. T. 2. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, p. 3. Já se escreveu: "As coisas não são apenas coisas. Carregam também um destino e são dotadas de memória. Objetos que guardam uma história conosco não podem ser postos a falar de nossa intimidade sem que nisso consintamos. Quem penetra o santuário da privacidade, diretamente ou por interpostos objetos, está avançando sobre um território interdito e se fazendo autor de lesão maior ou menor à dignidade humana" (VILLELA, João Baptista. A placenta e os direitos da mulher. *Del Rey Revista Jurídica*. Belo Horizonte, ano 4, n. 9, p. 9-10, set./nov., 2002, citado por: SÁ, Maria de Fátima Freire; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira. *Manual de Biodireito*. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 196).

[28] A Constituição da República, em seu art. 225, § 1º, VII, é explícita ao vedar práticas que "provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade". A lei dos crimes ambientais (Lei n. 9.605/1998), em seu art. 32, § 1º, prevê que incide na pena do *caput* quem "realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos".

[29] FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. *Curso de direito ambiental brasileiro*. São Paulo: Saraiva, 2013.

existencial – no caso da dignidade da pessoa humana, a nós mesmos –, é possível o reconhecimento do valor dignidade como inerente a outras formas de vida não humanas. A própria vida, de um modo geral, guarda consigo o elemento dignidade"[30].

Argumenta-se ainda ser possível, à luz de uma biologia filosófica, reformular a compreensão ética da atual relação entre ser humano e Natureza, afirmando-se haver algo de espiritual e transcendente na própria base da vida[31]. Uma concepção não "especista" da dignidade aceita, portanto, que ela se comunique para outros seres vivos. Que os animais não humanos, portanto, também estariam protegidos pelo vetor normativo da dignidade (nesse sentido, a Constituição Suíça inovou ao mencionar, em 1992, a "dignidade da criatura". A proteção é dirigida fundamentalmente às questões envolvendo engenharia genética). Supera-se, assim, o antropocentrismo kantiano, com uma proteção mais ampla, à luz da Constituição. Sustenta-se ser "difícil de conceber que o constituinte, ao proteger a vida de espécies naturais em face da sua ameaça de extinção, estivesse a promover unicamente a proteção de algum valor instrumental de espécies naturais; pelo contrário, deixou transparecer uma tutela da vida em geral nitidamente não meramente instrumental em relação ao ser humano mas numa perspectiva concorrente e interdependente"[32].

A matéria, contudo, persiste polêmica e não há unidade de vistas. Podemos concluir que se ainda não estamos prontos, à luz das estruturas e funções do nosso sistema jurídico, para reconhecer a posição de sujeito de direito para os animais, isso não significa que possamos instrumentalizá-los como coisas, sem consideração específica com seres que merecem consideração específica. Parece-nos fora de dúvida, atualmente, à luz dos postulados éticos de nosso sistema jurídico, que é dever do Estado e da sociedade tratar os animais sem crueldade. Não só isso: deve-se, por todos os modos e por todas as formas, com os instrumentos jurídicos disponíveis, reduzir o sofrimento de seres que sentem dor. Trata-se de questão ética relevante a que o direito do século XXI não pode permanecer indiferente, sob velhas escusas formais.

5.1.2. Uma visão legislativa recente: seres dotados de sensibilidade

Conforme já frisamos, os países que largaram na frente em relação ao tema foram Alemanha, Suíça, Áustria e França. Os três primeiros (Alemanha, Suíça e Áustria) deixaram claro em seus códigos que os animais não são coisas ou objetos. A França, em 2015, deu um passo além: introduziu uma proteção afirmativa, ao afirmar que os animais são seres vivos dotados de sensibilidade. Cabe registrar, na mesma linha, que o Código Civil português foi alterado, em 2017, a partir do chamado Estatuto Jurídico dos Animais. A norma prevê que "o direito de propriedade de um animal não abrange a possibilidade de, sem motivo legítimo, infligir dor, sofrimento ou

[30] SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Algumas notas sobre a dimensão ecológica da dignidade da pessoa humana e sobre a dignidade da vida em geral. *Direito ambiental atual*. TRENNEPOHL, Curt; TRENNEPOHL, Terence (Coords). São Paulo: Elsevier, 2014, pp. 83-100, p. 94.

[31] JONAS, Hans. *O princípio da vida*. Trad. Carlos Almeida Pereira. Petrópolis: Vozes, 2004, p. 15.

[32] SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Algumas notas sobre a dimensão ecológica da dignidade da pessoa humana e sobre a dignidade da vida em geral. *Direito ambiental atual*. TRENNEPOHL, Curt; TRENNEPOHL, Terence (Coords). São Paulo: Elsevier, 2014, pp. 83-100, p. 96.

quaisquer outros maus tratos que resultem em sofrimento injustificado, abandono ou morte" (Código Civil português, art. 1.305-A, 3). O Estatuto começou a vigorar em 01 de maio de 2017. Nesse contexto, o direito português caminha no sentido de reconhecer aos animais uma nova qualificação jurídica. Não seriam mais coisas – neutras e disponíveis – no sentido jurídico, como sempre foram enxergados. Teriam uma qualificação intermédia entre a coisa e o ser humano. O Estatuto português reconhece os animais como "seres dotados de sensibilidade e objeto de proteção jurídica". Prevê ainda que em caso de separação entre casais, "os animais de companhia são confiados a um ou ambos os cônjuges, considerando, nomeadamente, os interesses de cada um dos cônjuges e dos filhos do casal e também o bem-estar do animal" (Código Civil português, art. 1.793-A).

Conforme já lembramos, o STJ, em 2018, garantiu a ex-companheiro o direito de visitar animal de estimação após dissolução de união estável. Com a decisão, o ex-companheiro teve garantida a possibilidade de visitar uma cadela *yorkshire* que ficou com a mulher depois da separação. O relator destacou: "Penso que a solução deve, realmente, depender do caso concreto, mas será resguardada a ideia de que não se está frente a uma 'coisa inanimada', mas sem lhe estender a condição de sujeito de direito. Reconhece-se, assim, um terceiro gênero, em que sempre deverá ser analisada a situação concreta, voltado para a proteção do ser humano e seu vínculo afetivo com o animal".

5.2. Farra do boi e vaquejadas: o olhar do STF

Aliás, a vedação de práticas cruéis contra animais recebe clara repulsa não só social (embora muitas vezes difusa), mas também da jurisprudência do STF. Nesse sentido, já foram reconhecidas as inconstitucionalidades da prática da "farra do boi", e também da lei da regulamentava a "briga de galo". Não cabe alegar práticas comunitárias arraigadas para continuar com determinados costumes, se cruéis contra os animais. Assim, "a obrigação do Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância da norma do inciso VII do artigo 225 da Constituição Federal, no que veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Procedimento discrepante da norma constitucional denominado farra do boi" (STF, REXT, 153.531-8- SC, Rel. Min. Francisco Rezek). Lembremos que "o Direito é também um protagonista na ação evolutiva da sociedade humana; por isso, ele não se constrói *in abstracto*, à míngua de realidades concretas. Isso tanto mais se constata, com clareza, que a universidade e outras instituições andam à busca de estudos e ações interdisciplinares"[33].

Em relação à briga de galo, reconheceu-se a submissão desses animais a tratamento cruel, o que a Constituição Federal não permite (STF, ADI 1.856-6 – RJ, Rel. Min. Carlos Veloso, Pleno). Em suma, buscamos atualmente um olhar menos setorizado e mais interdisciplinar. Buscamos uma visão integrada e dinâmica do ordenamento jurídico, aceitando influências não imediatamente legislativas como contribuições – eventualmente valiosas – para a solução dos conflitos numa sociedade progressivamente plural e complexa. Buscamos, pois, por muitas formas e por muitos modos, construir

[33] MILARÉ, Édis. *Direito do Ambiente*. São Paulo: RT, 2014, p. 10.

instrumentos menos imperfeitos que propiciem diálogos proporcionais e razoáveis. Com isso, reduziremos, espera-se, os terríveis efeitos da degradação ambiental e sua pluralidade difusa de vítimas. Enfim, que possamos, como dissemos no início do capítulo, recuperar o tempo perdido e, quando olharmos para trás – daqui a algumas décadas ou alguns séculos – não nos envergonharmos, como sociedade, do que fizemos com a natureza e com as demais espécies animais no século XXI.

O STF, em 2016, julgou inconstitucional uma lei estadual que regulamentava a vaquejada. O tribunal entendeu haver "crueldade intrínseca" na prática. Para o relator, o sentido da expressão "crueldade", constante no inciso VII do parágrafo 1 do art. 225 da Constituição Federal alcança a tortura e os maus tratos infligidos aos bois durante a vaquejada (STF, ADI 4983). Poucos meses depois, no mesmo ano, o Congresso Nacional aprovou uma lei que equiparou a vaquejada aos rodeios, considerando-os "expressões artístico-culturais", tendo a "condição de manifestações da cultura nacional e de patrimônio cultural imaterial" (Lei n. 13.364, de novembro de 2016). O Brasil, em 2017, alterou sua Constituição para fazer constar no art. 225, § 7º: "Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos". A norma claramente resultou de uma resposta do Congresso Nacional às decisões do STF que consideraram a vaquejada uma prática cruel. O Brasil, com essa norma, vai na contramão das legislações mais atuais acerca do tema.

6. FIM DA PERSONALIDADE DA PESSOA HUMANA

> *"Que aqueles que foram meus amigos não precisassem esquecer ou disfarçar meus defeitos para que me estimassem depois de morto, e me recordassem como a um homem – vago bloco de coisas – capaz de ser tolerado e possível de ser útil".*
>
> Rubem Braga

Para o direito, a personalidade da pessoa humana, que tem início no nascimento com vida (Código Civil, art. 2º), finda com a morte. O direito civil, tradicionalmente, classifica as espécies de morte conforme veremos nos próximos tópicos.

6.1. Morte real

> *"Não gostaria de escolher entre o céu e o inferno. Tenho amigos nos dois".*
>
> Mark Twain

Consiste no fim das funções vitais. A medicina, e não o direito, é que definirá quando ocorre efetivamente a morte. No passado, tínhamos as batidas cardíacas. O melhor critério, atualmente, parece ser a morte encefálica, incluindo o tronco

encefálico[34]. A morte deverá ser atestada por médico, que pormenorizará a causa e o momento do falecimento. A ordem jurídica brasileira adota, atualmente, não o conceito de morte em virtude de parada cardiorrespiratória, mas sim o conceito de morte encefálica (ver, por exemplo, o art. 3º da Lei n. 9.434/97, que condiciona a retirada de órgãos *post mortem*, para transplante, à constatação da morte encefálica, a ser feita por pelo menos dois médicos. Cabe vale destacar que o Decreto n. 9.175/2017 regulamenta a lei citada, dispondo sobre a disposições de órgãos, tecidos, células e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento). O fato jurídico da morte repercute em vários institutos e normas do direito civil[35]. A Lei n. 13.484, de 2017, alterou a Lei de Registros Públicos e determinou: "Nenhum sepultamento será feito sem certidão do oficial de registro do lugar do falecimento ou do lugar de residência do *de cujus*, quando o falecimento ocorrer em local diverso do seu domicílio, extraída após a lavratura do assento de óbito, em vista do atestado de médico, se houver no lugar, ou em caso contrário, de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte".

6.2. Morte civil

Trata-se de tópico que traduz notícia histórica, não sendo admissível na atualidade. No direito romano, certas pessoas, mormente escravos, embora biologicamente vivos, eram tidos como se mortos fossem, perdendo todos os direitos civis, não podendo, sequer, vir a adquirir novos direitos. O *Code de Napoleón* (1804), em sua redação original, previa a morte civil. Naturalmente, uma tal sanção seria, na atualidade, claramente afrontosa à dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil. Aliás, Teixeira de Freitas, nosso genial civilista do século XIX, sempre louvado por Pontes de Miranda, já considerava a morte civil "uma monstruosa instituição". Teixeira de Freitas, também, de modo revolucionário, recusou-se a inserir a escravidão em seu *Esboço de Código Civil*, mesmo a escravidão existindo, legalmente, na época.

6.3. Morte presumida

> *"Que o mistério que existe em toda morte fosse na minha dignificado pela simplicidade. E meu velório fosse assim como que uma festinha de despedida, onde mesmo as pessoas que ficassem como os olhos vermelhos pudessem rir sem remorso. E aqueles que fossem saindo pensassem apenas: "vamos a um bar; ele só não vai porque não pode"; e assim manifestassem confiança em mim".*
>
> Rubem Braga

[34] Cf. VILLAS-BÔAS, Maria Elisa. A morte encefálica como critério de morte. *Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia*. Salvador, n. 17, 2008, p. 42.

[35] A morte, na classificação dos fatos jurídicos – que adiante estudaremos –, qualifica-se como fato jurídico *stricto sensu*. Assim, "a morte em si é sempre fato jurídico *stricto sensu*, não mudando de categoria em razão de sua causa" (MELLO, Marcos Bernardes de. *Teoria do Fato Jurídico. Plano da Eficácia*. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 170). Ehrhardt lembra que a extinção da personalidade civil do ser humano provoca: a) a abertura da sucessão (Código Civil, art. 1.784); b) a dissolução da sociedade conjugal (Código Civil, art. 1.571, I); c) a extinção do poder familiar (Código Civil, art. 1.635, I); d) a cessação do dever de prestar alimentos (Código Civil, art. 1.700); e) a extinção dos contratos personalíssimos; f) a extinção do usufruto estipulado em favor do falecido (Código Civil, art. 1.410, I); g) a extinção do pacto de preempção ou preferência (Código Civil, art. 520)". (EHRHARDT JR, Marcos. *Direito Civil*. v. 1. Salvador: Juspodivm, 2009, p. 153).

O Código Civil trata da morte presumida separando-a em duas subespécies distintas, conforme veremos a seguir.

6.3.1. Morte presumida sem decretação de ausência

Prescreve o art. 7º: "Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência: I – se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida; II – se alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até 2 (dois) anos após o término da guerra". Se alguém, por exemplo, um brasileiro, estava trabalhando no *World Trade Center* no dia 11 de setembro de 2001, e, até hoje, seu corpo não foi encontrando. Trata-se de morte cuja probabilidade de ter ocorrido é imensa, praticamente certa. Pode, portanto, em relação a ele, ser declarada sua morte presumida, inclusive com certidão de óbito dada à família. O inciso II trata da hipótese de alguém desaparecido em guerra ou feito prisioneiro, que não for encontrado até dois anos depois de finda a guerra. Também neste caso poderá ser-lhe declarada a morte presumida. O parágrafo único do art. 7º estabelece que a declaração de morte presumida, nesses casos (tanto para o inciso primeiro como para o inciso segundo), somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. É possível, entretanto, que a pessoa que todos imaginavam morta na verdade não esteja. As *Jornadas de Direito Civil*, em 2018, entenderam que "os efeitos patrimoniais da presunção de morte posterior à declaração da ausência são aplicáveis aos casos do art. 7º, de modo que, se o presumivelmente morto reaparecer nos dez anos seguintes à abertura da sucessão, receberá igualmente os bens existentes no estado em que se acharem" (Enunciado 614).

6.3.2. Morte presumida com decretação de ausência

O Código Civil determina no art. 6º: "A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva". Veremos mais adiante, ao cuidar da ausência, que a tutela do ausente e dos seus bens observa três fases, sendo a última delas a sucessão definitiva. É apenas nesta última fase que a morte do ausente é presumida de acordo com o Código Civil[36].

[36] Marcos Bernardes de Mello escreveu que "termina a personalidade (i) com a morte natural, (ii) presumindo-se esta, no direito brasileiro: (ii.1) *em relação ao ausente*: (a) após o decurso de dez anos a partir do trânsito em julgado da sentença que determinar a abertura da sucessão provisória, ou (b) se contar mais de 80 anos de idade, haja decorrido cinco anos das últimas notícias suas" (MELLO, Marcos Bernardes de. *Teoria do Fato Jurídico. Plano da Eficácia*. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 168-169).

6.4. Comoriência

Define-se, em geral, a comoriência como a morte simultânea de pessoas que são reciprocamente herdeiras. Tem como pressupostos cumulativos: a) morte na mesma ocasião; e b) impossibilidade de verificar, por meios técnicos, quem faleceu primeiro.

A questão pode ser posta do seguinte modo: se duas ou mais pessoas falecem ao mesmo tempo – num acidente de ônibus, por exemplo – e há, entre elas, relações sucessórias, como definir qual faleceu primeiro, se a perícia médico-científica não tem condições de definir a ordem dos falecimentos? O instituto da comoriência responde: a presunção é que eles faleceram ao mesmo tempo. Estatui o art. 8º do Código Civil: "Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos". Perto da virada de ano de 2014 para 2015, houve um lamentável e triste acidente nas proximidades de Belo Horizonte, que resultou no falecimento de conhecido professor de direito, sua esposa e os dois filhos menores do casal. Além das terríveis dimensões humanas que casos assim sempre envolvem, sob o aspecto jurídico teríamos configurado o instituto da comoriência.

Pode-se ainda perguntar: qual a relevância de se saber a ordem dos falecimentos? Tal ordem é relevante para o direito das sucessões. Imaginemos um casal, sem descendentes ou ascendentes, que falece num trágico acidente de carro. Se a perícia comprova que ele faleceu primeiro do que a esposa, ela, a esposa, herda os bens do marido, o os transmite para seus familiares. Já se o contrário ocorrer – a perícia comprovar que ela faleceu antes do que ele –, os bens irão para os familiares dele. Se ambos faleceram ao mesmo tempo, ou se a perícia não puder comprovar qual a ordem dos falecimentos, aplica-se a comoriência, cuja solução é esta: a presunção de que ambos faleceram ao mesmo tempo. Os bens serão divididos entre os familiares de ambos os cônjuges. A comoriência, portanto, tem sua razão de ser nas consequências que traz: torna intransmissíveis os bens entre os comorientes. É como se, entre eles, não houvesse vínculo sucessório.

Por fim, uma observação não jurídica. É incrível como a vida sempre supera nossa imaginação. Seja em situações felizes, seja em situações tristes. Em 2017 a imprensa americana noticiou um acidente: dois carros colidiram de frente numa estrada, em razão da ultrapassagem indevida feita por um deles. Um caso, embora triste, seria comum, não fosse por uma brutal circunstância: num dos carros estava o pai, no outro o filho. Ambos morreram no mesmo acidente. Também em 2017, em Belo Horizonte – o exemplo não diz respeito à comoriência, mas também nos choca e entristece – um motorista do Samur (serviço médico de atendimento de urgência), ao conduzir os médicos para um atendimento, teve um impacto ao chegar: o rapaz, morto no acidente de moto, era seu filho.

7. AUSÊNCIA

"E no meio dessa confusão alguém partiu sem se despedir; foi triste. Se houvesse uma despedida talvez fosse mais triste, talvez tenha sido melhor assim, uma separação como às vezes acontece em um baile de carnaval – uma pessoa se perde da outra, procura-a por um instante e depois adere a qualquer cordão. (...). Creio que será permitido guardar uma leve tristeza, e também uma lembrança boa; que não será proibido confessar que às vezes se tem saudades; nem será odioso dizer que a separação ao mesmo tempo nos traz um inexplicável sentimento de alívio, e de sossego; e um indefinível remorso; e um recôndito despeito".

Rubem Braga

7.1. Quem é ausente para o direito civil?

Ausente é aquele que desaparece do seu domicílio sem deixar notícia. Porém, mesmo que tenha desaparecido sem deixar notícias, poderá ter deixado representante ou procurador a quem caiba administrar os bens (Código Civil, art. 22). Porém, se o mandatário (representante ou procurador) não quiser ou não puder, por qualquer razão, exercer ou continuar a exercer o mandato, ou não tiver poderes suficientes para tanto, a ausência será judicialmente decretada. O Código Civil de 1916 considerava o ausente absolutamente incapaz – escolha que era bastante criticada (o ausente, digamos, onde quer que se encontre, continua capaz, se estiver vivo)[37]. O Código Civil de 2002 trata a ausência na parte geral, mas fora do rol dos incapazes. Nesse contexto, "ausência é a presunção da morte da pessoa física, para fins civis, em virtude de desconhecimento de seu paradeiro, após longo tempo e cujas circunstâncias levam a fundadas dúvidas da continuação de sua existência"[38].

É quase sempre dramático, para os familiares, a busca por quem desapareceu e a incerteza sobre seu destino. O direito, muitas vezes, opta por presumir aquilo que não podemos, na realidade da vida, afirmar (presume, por exemplo, a morte daquele que estava no avião que caiu no mar, mas cujo corpo jamais foi encontrado). Em 2014 uma oficial da aeronáutica desapareceu em Belo Horizonte. Seus pais e irmãos se desesperaram. Meses depois, por acaso, um agricultor encontrou destroços de um carro num local de difícil acesso, em mata fechada. O carro tinha despencado de um abismo no caminho entre Belo Horizonte e Ouro Preto. Suspeita-se de suicídio, porque havia um quadro de depressão e a moça, antes de sumir, transferiu o dinheiro de sua conta para a conta bancária da irmã. São casos tristemente dramáticos. A família, muitas vezes, prefere a notícia mais trágica (a confirmação da morte) a continuar numa dolorosa incerteza angustiante.

[37] Caio Mário, por exemplo, escrevendo sob a égide do Código Civil anterior, argumentava: "Nosso direito ainda conserva uma deformação conceitual cientificamente injustificável: considera o ausente um incapaz. Ausente é aquele que desaparece de seu domicílio, sem que dele se tenha notícia. Dá-se um administrador aos seus bens; partilha-se o seu patrimônio; não porque seja ele um incapaz, mas porque sua fazenda necessita de gerência, e ainda porque o prolongado afastamento da direção de seus negócios induz a presunção de sua morte" (PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de Direito Civil*. v. V. *Direito de Família*. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 270).

[38] LÔBO, Paulo. *Direito Civil. Parte Geral*. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 133.

correndo, portanto, contra eles as ações pendentes e aquelas que vierem a ser propostas. Percebe-se que aqui o legislador tenta conciliar a proteção dos interesses do ausente com os interesses dos sucessores e credores. Essa fase – sucessão provisória – durará, em regra, 10 anos (contados do trânsito em julgado da decisão que abre a sucessão provisória). O prazo se reduz para 5 anos se o ausente tiver mais de 80 anos e de mais de 5 anos datarem suas últimas notícias (Código Civil, art. 38). Esta fase se encerra: a) pela confirmação da morte do ausente; b) pelo seu retorno; c) pela abertura da sucessão definitiva. O CPC/2015 prevê que presentes os requisitos legais, poderá ser requerida a conversão da sucessão provisória em definitiva.

7.2.3. Sucessão definitiva

Conforme destacamos no item anterior, esta fase só pode ser solicitada depois de 10 anos do trânsito em julgado da sentença que concede a abertura da sucessão provisória (Código Civil, art. 37). Na última fase, da sucessão definitiva, os herdeiros podem solicitar o levantamento das garantias prestadas, adquirindo assim o domínio dos bens deixados. Frise-se, no entanto, que tal domínio será resolúvel, uma vez que o ausente, se e quando regressar, a eles terá direito, porém no estado em que se encontrarem (Código Civil, art. 39). Porém o ausente só terá esse direito se retornar até 10 anos contados da abertura da sucessão definitiva. Depois disso, não mais terá direito aos bens. Não deixa de ser cruel, em certos casos, a solução legal. Há casos espantosos em que a ausência dura décadas e não é voluntária. Basta lembrar, a propósito, do filme *Náufrago*, com Tom Hanks, baseada em fatos reais (em 2014 um homem foi resgatado após permanecer 13 meses à deriva no Oceano Pacífico). Os piores danos, em casos assim, certamente nem são patrimoniais, mas existenciais e afetivos. E há casos bárbaros e horrendos, ainda piores. O caso de Cleveland (Estados Unidos), por exemplo, é espantoso. Ariel Castro manteve, no porão de sua casa, três mulheres reféns durante mais de 10 anos, sem que ninguém desconfiasse. Uma delas engravidou do criminoso pelo menos cinco vezes.

7.3. A ausência no CPC/2015

Como tantos outros institutos que recebem disciplina simultânea do Código Civil e do Código de Processo Civil, é imperioso observar, em relação à ausência, não só as regras de direito material, mas também aquelas provindas do direito processual. Aliás, a ausência, no Brasil, é tradicionalmente regulada no Código Civil e no Código de Processo Civil (foi assim no Código Civil de 1916 e no CPC de 1973 e, também, no Código Civil de 2002 e no CPC de 2015). Pontes de Miranda lembra que "o que se muda nas leis não destrói, sempre, os princípios, e as alterações revelam o que se teve por fito, acertada ou erradamente. O que importa é que as obras se cinjam aos dados jurídicos atuais e à necessária atenção aos textos"[43].

[43] O notável jurista lembra que "há grande vantagem em se estudar, tratar e expor o direito, aprofundando-se-lhe os princípios". Recomenda, ainda, que busquemos o sentido histórico das instituições e da técnica legislativa (PONTES DE MIRANDA: *Comentários ao Código de Processo Civil*. T. I. Rio de Janeiro: Forense, 1997, prólogo).

Convém registrar, inicialmente, que a ação em que o ausente for réu será proposta no foro de seu último domicílio (CPC/2015, art. 49). Este também será competente para a arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições testamentárias do ausente. Mencionamos acima que deverá haver, em relação à ausência, declaração judicial. O juiz mandará arrecadar os bens do ausente e nomeará curador de seus bens. O CPC/2015 prevê ainda que o interessado, ao requerer a abertura da sucessão provisória, pedirá a citação pessoal dos herdeiros presentes e do curador e, por editais, a dos ausentes para requererem habilitação. Regressando o ausente ou algum dos seus descendentes ou ascendentes para requerer ao juiz a entrega de bens, serão citados para contestar o pedido os sucessores provisórios ou definitivos, o Ministério Público e o representante da Fazenda Pública, seguindo-se o procedimento comum.